עותק לפרסום – הושחרו פרטים מזהים של אנשים פרטיים לשם הגנה על פרטיותם.

בית משפט השלום בתל אביב - יפו

ת"א 24422-07-16 [redacted] ואח' נ' רום ארד הנדסה בע"מ ואח'

לפני כבוד השופט פנינה נויבירט

התובעים:
1. [redacted]
2. [redacted]

נגד

הנתבעים:
1. רום ארד הנדסה בע"מ
2. אוריון שיא ניהול והנדסה בע"מ (בהקפאת הליכים)
3. [redacted]

ב"כ התובעים עו"ד דב דוניץ ועו"ד גל הרינג
ב"כ הנתבעת 1 עו"ד גל נהיר שפר
ב"כ הנתבע 3 עו"ד רון זהבי

<u>פסק דין</u>

<u>פתח דבר</u>

1. ביום 17.11.13 נכרת הסכם בין התובעים לבין הנתבעת 1, חברת רום ארד הנדסה בע"מ (להלן: "רום ארד") למכירת דירת פנטהאוז בת 6 חדרים, שנבנתה בפרויקט ארגמן, בכתובת רח' [redacted] בנס ציונה (להלן: "הדירה"). לדירה הוצמדו מחסן ושני מקומות חניה תת קרקעיים (להלן: "ההסכם").

בנספח תוספות למפרט הטכני של הדירה, שצורף להסכם המכר, הוסכם על ביטול המחסן הצמוד, על הסבתו לחדר אמבטיה ועל הכללתו בשטח הדירה, וזאת "באופן ובמועד לפי החלטת החברה". כמו כן הוסכם, כי השינויים שבנספח זה יהיו "בהתאם לחוק התכנון והבניה, לתקנים מחייבים ולאילוצי תכנון וקונסטרוקציה". אך בסופו של יום המחסן הצמוד לא הוסב לחדר אמבטיה ולא הוכלל בשטח הדירה. מעבר לכך, הצדדים נחלקו בדבר מועד מסירת הדירה, וכן בדבר ליקויים ואי התאמות בדירה. התובעים הגישו תביעה זו לפיצוי בגין הפרת ההתחייבות הנטענת לכלול את המחסן כשטח עיקרי בדירה, בגין איחור במסירת הדירה ובגין ליקויים ואי התאמות.

<u>רקע כללי וטענות הצדדים</u>

2. התובעים, ה"ה [redacted] הם אנשים פרטיים. הנתבעת 1, חברת רום ארד הנדסה בע"מ (להלן: "רום ארד"), היא חברה יזמית, העוסקת בתחום הנדל"ן למגורים, שבנתה את פרויקט ארגמן ברח' [redacted] בנס ציונה. הנתבעת 2, אוריון שיא ניהול והנדסה בע"מ (להלן: "אוריון") היתה הקבלן המבצע של פרויקט ארגמן. הנתבע 3, מר [redacted] הוא הבעלים של אוריון (להלן: "[redacted]").

ביום 17.11.13 רכשו ה"ה [redacted] את הדירה מרום ארד. לדירה הוצמדו מחסן ושני מקומות חניה תת קרקעיים.

בנספח תוספות למפרט הטכני של הדירה – שהיווה נספח להסכם המכר, ושנחתם אף הוא ביום 17.11.13 (להלן: "המפרט הטכני"), הוסכם, בין היתר, על "ביטול מחסן צמוד באופן ובמועד לפי החלטת החברה והפיכתו לחדר אמבטיה שירותים מקלחת וכיור". כמו כן הוסכם כי כל השינויים המפורטים בנספח זה יהיו "בהתאם לחוק התכנון והבניה, לתקנים מחייבים ולאילוצי תכנון וקונסטרוקציה".

לאחר כריתת הסכם המכר, החלו פגישות וחילופי תכתובות בין הצדדים, במסגרתן נבחנו טענותיהם של התובעים לאי התאמות בין המפרט הטכני לבין המציאות בשטח ולעניין הסבת המחסן לחדר אמבטיה. לאחר פגישות מרובות, הגיעו ה"ה [redacted] ורום ארד להסכמה בפגישה שהתקיימה ביום 14.5.14, לפיה עבודות הסבת המחסן לחדר אמבטיה תבוצענה בידי קבלן שיפוצים חיצוני לאחר קבלת טופס 5 (גמר) לבניין, כאשר רום ארד תישא בעלות ביצוע העבודות ונציג הקבלן יפקח על ביצוען.

ביום 5.8.14 הסכימו ה"ה [redacted] כי עבודות הסבת המחסן תבוצענה על ידי "[redacted]" מהחברה", או על ידי קבלן משנה של הקבלן בפרויקט – חברה העונה לשם "גיה". כמו כן חתמו ה"ה [redacted] במעמד פגישה זו על "חשבון שינויים", בו נכללה הסכמה על דחיית מועד המסירה ב- 120 ימי עבודה ממועד החתימה.

ביום 20.11.14 חתמו ה"ה [redacted] על פרוטוקול מסירה של הדירה, וזאת לאחר שהסדירו את יתרת התשלום עבור הדירה, אך טרם הושלמו העבודות בדירה. בין ה"ה [redacted] לנציגי רום ארד התקיימו שיחות טלפון, חילופי תכתובות ופגישות במשך חודשים לאחר החתימה על פרוטוקול המסירה. בכלל זה, ביום 27.5.15 נפגש מר [redacted] (להלן: "[redacted]") עם מר [redacted] מטעם רום ארד (להלן: "[redacted]") בדירה, והשניים ערכו פרוטוקול עבודות בדירה, המתעד את העבודות הטעונות השלמה בדירה. גם לאחר פגישה זו התקיימו בין הצדדים שיחות טלפון וחילופי תכתובות בנוגע להשלמת העבודות.

לטענת ה"ה [redacted] רק באמצע חודש אוגוסט 2015, באיחור של 14 חודשים ממועד המסירה החוזי, נכנסו ה"ה [redacted] לדירה. גם לאחר הכניסה לדירה התקיימו בין הצדדים שיחות טלפון וחילופי תכתובות בנוגע להשלמת העבודות.

בנוסף, העלו ה"ה [redacted] טענות לליקויי בנייה בדירה. במסגרת הליך זה הגישו הצדדים חוות דעת מומחים מטעמם ומהנדס הבניין והשמאי מר [redacted] מונה כמומחה מטעם בית המשפט.

בהחלטה מיום 22.11.21 עוכבו ההליכים נגד אוריון, בעקבות צו פתיחת הליכים במסגרת הליכי חדלות פירעון בעניינה.

3. לטענת ה"ה [redacted] רום ארד התחייבה להסבת המחסן בדירה לחדר האמבטיה במסגרת נספח התוספות למפרט הטכני, אשר הוא חלק מהסכם המכר. רום ארד הפרה את התחייבותה להסבת המחסן, ועליה לפצותם בגין כך.

ה"ה [redacted] הכחישו את טענתה רום ארד, כי התברר לה רק לאחר החתימה על הסכם המכר כי הסבת המחסן אינה אפשרית. הם טענו, כי נושא הסבת המחסן עלה כחודש וחצי קודם לכריתת הסכם המכר, וכי במועד זה ידעה רום ארד כי הסבת המחסן אינה תואמת את היתר הבניה. ה"ה [redacted] טענו כי הם לא היו מודעים לכך שרום ארד אינה מתכוונת לבצע את הסבת המחסן ולעמוד בהתחייבותה החוזית קודם לכריתת ההסכם.

ה"ה [redacted] הכחישו כי רום ארד העמידה לפניהם את האפשרות לבטל את הסכם המכר לאחר שהודיעה להם כי הסבת המחסן אינה אפשרית. כמו כן טענו, כי מעולם לא הסכימו לקחת על עצמם את האחריות לביצוע הסבת המחסן.

ה"ה [redacted] טענו, כי ניתן לראות בכל פרוטוקול והתכתבות בין הצדדים את התנגדותם להצעת רום ארד לבצע בעצמם את הסבת המחסן. עוד טענו, כי רום ארד הפעילה עליהם מניפולציות ועשתה הכל על מנת לגלגל האחריות לעניין הסבת המחסן עליהם או על קבלן חיצוני אחר, ממנו התנערה, וכן כי רום ארד נקטה בגישה אגרסיבית של עיכוב הבניה על מנת להפעיל עליהם לחץ, ולכפות עליהם את רצונה. לדבריהם, התנהלות רום ארד לא השאירה להם ברירה, למרות התנגדותם, שכן הם ידעו כי ללא שיתוף פעולה ע[redacted] ארד לא יוכלו לקבל את החזקה בדירה בעתיד הנראה לעין, וכי על מנת למזער נזקים עליהם להיכנע בה הנתבעת מסכימה כביכול לבצע את התחייבותה. בנוסף, טענו ה"ה [redacted] כי רום ארד לא הביא ראיה לכך שה"ה [redacted] הם אלה שאכן ביצעו בפועל את הסבת המחסן.

על רקע האמור, טענו ה"ה [redacted] כי הם זכאים לפיצוי בגין ירידת ערך, כתוצאה מהסבת המחסן ללא ובגין עלויות השבת המחסן, בסך כולל של 573,000 ₪.

בנוסף טענו ה"ה [redacted] כי מועד המסירה החוזי היה ה- 30.6.14, וכי רק באמצע חודש אוגוסט 2015, כארבעה עשר חודשים לאחר מועד המסירה החוזי, נכנסו בפועל לדירה. על כן טענו ה"ה [redacted] כי יש לפצותם בפיצוי בגין איחור במסירה בסך של 234,000 ₪.

באשר לסיכום שהושג בדבר איחור במסירה של 120 ימי עבודה, בהתאם לפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 ולחשבון שינויים מיום 14.8.14, טענו ה"ה [redacted] כי מדובר היה במחווה מצידם, לטובת רום ארד, אך כי למעשה לא היתה הצדקה לאיחור במסירה, וכן כי הודיעו על ביטול ההסכמה בדבר איחור במסירה בעקבות התמהמהות רום ארד מביצוע העבודות בדירה.

ה"ה [redacted] לא הכחישו את חתימתו של [redacted] ע"ג פרוטוקול המסירה ביום 20.11.14. אך הם טענו מדובר בפרוטוקול מסירה פיקטיבי, שנועד לקידום עבודות הסבת המחסן, וכי בפועל הדירה לא היתה מוכנה למסירה במועד זה.

מעבר לכך, טענו ה"ה [redacted] כי הם זכאים לפיצוי בגין ליקויים ואי התאמות בדירה, כפי שנקבע בחוות דעת מומחה בית המשפט, המהנדס [redacted] ובחוות הדעת המשלימה מטעמו. כמו כן טענו ה"ה [redacted] כי הם זכאים לפיצוי בגין עגמת נפש.

ה "ה [redacted] טענו, כי אוריון נושאת באחריות חוזית לליקויים, אי ההתאמות ולאיחור במסירה של הדירה, וזאת מכוח הוראת סעיף סעיף 3.3 להסכם המכר. בנוסף, טענו ה"ה [redacted] כי יש להורות על הרמת מסך ההתאגדות שבין אוריון לבעליה, [redacted] בגין הליקויים, אי ההתאמות והאיחור במסירת הדירה.

4. לטענת רום ארד, מעולם לא התחייבה להסבת המחסן, שכן התחייבותה בעניין היתה התחייבות מותנית, שסויגה בכך שהשינוי ייעשה "באופן ובמועד לפי החלטת החברה". לדבריה, רק לאחר כריתת ההסכם ביצעה בדיקות, מהן גילתה, כי הסבת המחסן אינה אפשרית. רום ארד טענה, כי ה "ה [redacted] היו מודעים לאפשרות שלא ניתן יהיה לבצע את הסבת המחסן. הם קנו ביודעין סיכון, בהתקשרם בהסכם המכר במתכונת זו, והתנהלותם אינה מתיישבת עם חובת תום הלב במימוש זכות חוזית.

[redacted] בנוסף, טענה רום ארד, כי היא הודיעה לה"ה [redacted] כחודש וחצי בלבד לאחר החתימה על הסבת המחסן היא בלתי אפשרית, וכי העמידה בפני ה"ה [redacted] את האפשרות לבטל את הסכם חזרה את המקדמה ששולמה, באופן שלא יגרם להם כל נזק, או לקיים את ההסכם, בשינויים ה"ה [redacted] בחרו שלא לבטל את הסכם המכר.

רום ארד הפנתה להסכמות שהושגו בין הצדדים בפרוטוקול פגישה מיום 28.1.14 ובפרוטוקול פגישה מיום 5.8.14. לדבריה, הושג סיכום ביחס למספר עניינים שהיו שנויים במחלוקת, בהם הסבת המחסן, לסילוק סופי של טענות הצדדים, ועל כן מנועים ה"ה [redacted] מהעלאת טענות בעניין הסבת המחסן.

לדברי רום ארד, לכל היותר ה"ה [redacted] לפיצוי בגין עלות הכשרת הסבת המחסן. אך אין הם זכאים לפיצוי בגין השבת המצב לקדמותו בהתאם לתכנית הקיימת, במקרה בו הועדה המקומית לא תאשר את הסבת המחסן.

עוד הפנתה חברה לסיכום בין הצדדים אודות איחור במסירה של 120 ימי עבודה, בהתאם לפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 ולחשבון שינויים מיום 14.8.14. היא טענה כי עמדה בהסכמות אלה, שכן הדירה נמסרה במעמד החתימה על פרוטוקול המסירה של הדירה, ביום 20.11.14.

רום ארד העלתה שורה של השגות בדבר קביעותיו של המהנדס [redacted] בנוגע לליקויים ואי התאמות בדירה. היא אף טענה, כי יש לראות באוריון כמי שנושאת באחריות לליקויים, אי התאמות ואיחור במסירה.

5. לטענת [redacted] אוריון כלל לא היתה צד להסכם המכר, ואין בהוראותיו של הסכם המכר כדי לחייבה באחריות כלפי ה"ה [redacted] בגין ליקויים, אי התאמות ואיחור במסירת הדירה. אף לא ניתן לייחס לאוריון אחריות במישור הנזיקי, שכן לא היא השלימה את עבודות הגמר בדירה, וממילא נותק הקשר הסיבתי בין פעולותיה לבין טענותיהם של ה"ה [redacted] לליקויים, אי התאמות ואיחור במסירת הדירה.

עוד טען [redacted] כי אין מקום להרמת מסך ההתאגדות בעניינו, שכן לא הוכח כי עשה שימוש באישיותה המשפטית הנפרדת של אוריון באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה שלה, או באופן הפוגע בתכלית אוריון, תוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.

<u>דיון והכרעה</u>

6. הצדדים חלוקים בדבר אחריות רום ארד להסבת המחסן לחדר אמבטיה, בדבר ליקויים ואי התאמות בדירה, בדבר מועד מסירת הדירה, בדבר זכאות ה"ה [redacted] לפיצוי, וכן בדבר זהות הגורם האחראי לפיצוי ה"ה [redacted] בגין הליקויים, אי ההתאמות והעיכוב במסירת הדירה. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, את עדיהם ואת מומחה בית המשפט, ועיינתי בכל אשר הובא לפני, השתכנעתי כי דין התביעה כנגד רום ארד להתקבל בחלקה, וכי דין התביעה כנגד [redacted] להידחות.

<u>התחייבות רום ארד להסבת המחסן לחדר אמבטיה במסגרת הסכם המכר</u>

7. הצדדים חלוקים בדבר מחויבותה החוזית של רום ארד להסבת המחסן לחדר אמבטיה. הצדדים הרחיבו בסיכומיהם אודות הרקע לכריתת הסכם המכר, תניות הסכם המכר ונפקויותיהן, וכן אודות השלכותיה של הודעת רום ארד להי"ה [redacted] כי הסבת המחסן אינה אפשרית, לאחר כריתת הסכם המכר.

כפי שאפרט להלן, אכן בהסכם המכר נכללה התחייבות רום ארד להסבת המחסן כאמור. אף לא הוכח כי עמדה בפני הי"ה [redacted] האפשרות לבטל את הסכם המכר, אחר שרום ארד הודיעה להי"ה [redacted] כי הסבת המחסן אינה אפשרית, או כי היה בעצם העמדת האפשרות לביטול הסכם המכר כדי לשלול מהי"ה [redacted] פיצוי בגין אי עמידת רום ארד בהתחייבותה להסבת המחסן כאמור.

עם זאת, הצדדים הגיעו, בסופו של דבר, להסכמות לסילוק מוחלט של הטענות בעניין, במסגרתן לקחו על עצמם הי"ה [redacted] את ביצוע הסבת המחסן במימון רום ארד. הסכמות אלה שומטות הקרקע תחת תביעת הי"ה [redacted] בעילה זו.

אדון, אם כן, תחילה בהתחייבותה החוזית של רום ארד להסבת המחסן במסגרת הסכם המכר. בהמשך אדון בהסכמותיהם המאוחרות של הצדדים לפיהן הסבת המחסן תבוצע על ידי הי"ה [redacted] במימון רום ארד.

התחייבותה החוזית של רום ארד להסבת המחסן לחדר אמבטיה

8. הסכמות הצדדים בנוגע להסבת המחסן עוגנו בנספח תוספות למפרט הטכני של הדירה, שהיווה נספח להסכם, ושנחתם אף הוא ביום 17.11.13. במבוא לנספח התוספות למפרט הטכני נכתב, כי הוא "מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם המכר" ("והואיל" מס' 3).

בסעיפים 1 – 30 לנספח התוספות למפרט הטכני פורטו שינויים שיתוספו למפרט הטכני של הדירה. בסעיף 5 נכתב, כי למפרט הטכני של הדירה יתוסף השינוי הבא:

> "5. ביטול מחסן צמוד באופן ובמועד לפי החלטת רום ארד והפיכתו לחדר אמבטיה שירותים מקלחת וכיור"

משמע שרום ארד התחייבה לשנות את המפרט הטכני של הדירה על דרך ביטול המחסן הצמוד והסבתו לחדר אמבטיה.

9. לטענת רום ארד, מעולם לא התחייבה להסבת המחסן, שכן התחייבותה בעניין היתה התחייבות מותנית, שסויגה בכך שהשינוי ייעשה "באופן ובמועד לפי החלטת החברה". אך עצם הסייג לפיו הסבת המחסן תיעשה

באופן ובמועד לפי החלטת החברה כאמור, אין בו כדי ללמד על אפשרותה של רום ארד להתחמק מהתחייבות זו. כל שנכתב הוא, כי אופן הסבת המחסן ועיתויה – יהיו בידי רום ארד.

רום ארד הפנתה להוראת סעיף 31.3 לנספח התוספות למפרט הטכני בו נכתב:

"31.3. כל השינויים הנ"ל במפרט הטכני יהיו בהתאם לחוק תכנון והבניה, לתקנים מחייבים ולאילוצי תכנון וקונסטרוקציה."

כמו כן הפנתה רום ארד להוראת סעיף 3.1 להסכם, בהתאם לשינויים שהוכנסו בהוראה זו בסעיפים 10 ו-11 לנספח התיקונים להסכם, ששינתה את הוראת סעיף 3.1 להסכם, אשר זו לשונה:

"3.1. החברה מתחייבת כי הדירה תבנה על ידה באמצעות קבלן מטעמה, במומחיות נאותה, מחמרים טובים, בהתאם להיתר הבניה למפרט והתכניות הרצופים בזה כ**נספח ב'** (להלן: "**המפרט**"), בכפוף לשינויים מותרים בביצוע כהגדרתם במפרט, בכפוף לשינויים אם יהיה צורך לבצעם כתוצאה מהוראות הדין או מהנחיות הרשויות המוסמכות שלא על פי בקשת החברה ובכפוף לביצוע שינויים עליהם יוסכם בכתב באופן האמור בהסכם זה."

10. רום ארד טענה, כי מהוראות ההסכם עולה, כי "הצדדים סייגו" את ההסכמה להסבת המחסן, כי הסבת המחסן היתה "בגדר אפשרות בלבד שיכול שניתן יהיה לממשה ויכול שלא", כלשונה, וכי הדבר נתון עדיין לבדיקת רום ארד (סעיפים ב.1.1 ו- ב.2. לסיכומי רום ארד). זאת מאחר שההתחייבות להסבת המחסן כאמור הותנתה בכך שתהיה כפופה לחוק התכנון והבניה, לתקנים המחייבים ולאילוצי תכנון וקונסטרוקציה. רום ארד טענה עוד, כי תניות אלה נוסחו ביחד עם עורך דינם של ה"ה [redacted]

אך טענותיה אלה של רום ארד אינן עולות מפשט לשון הוראות ההסכם ונספחיו. אין בתניות ההסכם ונספחיו הבהרה ברורה ומפורשת, כי ההתחייבות להסבת המחסן כפופה ל"בדיקת החברה", וכי היא מסויגת ובגדר אפשרות בלבד. אף אין כל התייחסות בהסכם ובנספחיו למשך הזמן בו אמורה להתבצע בדיקה רום ארד של היתכנות הסבת המחסן וכן לנפקות הכספית של אי הסבת המחסן במקרה בו האפשרו לא תצא אל הפועל. על כן אין די בהפניה להוראות כלליות בנספח התוספות למפרט הטכני או בהסכם, הכפפת כלל תניות ההסכם להוראות הדין ולהנחיית הרשויות המוסמכות.

[redacted]

הוראות כלליות אלה, עליהן נסמכה רום ארד, אינן יכולות להכשיר כשלעצמן התחייבויות חוזיות רום ארד. רום ארד היתה מודעת לכך שהתחייבויות אלה הן בגדר אפשרות בלבד, ועם זאת כללה אותן בהסכם, וקיבלה תמורה בגינן. אף אין לקבל את טענת רום ארד, כי על ה"ה [redacted] לשאת בהשלכות אי קיום האפשרות הנטענת להסבת המחסן, על דרך תשלום מלוא התמורה החוזית, חרף אי הסבת המחסן כאמור.

אף לא מצאתי ביסוס ראייתי לטענת רום ארד בדבר מעורבות עורך דינם של ה"ה [redacted] בניסוח תניות אלה. רום ארד הפנתה , בהקשר זה, לעדות שמסר [redacted] בחקירתו הנגדית, אך בעדותו הבהיר [redacted] כי סעיף 31.3 לנספח התוספות למפרט הטכני הוכנס על ידי רום ארד (עמ' 71, שורות 19 – 20), ולא נדרש לזהות המנסח של יתר התניות הרלוונטיות.

עוד הפנתה רום ארד לתשריט שצורף להסכם, עליו חתמו ה"ה [redacted] ואשר אינו כולל את הסבת המחסן. לדבריה, יש בכך כדי ללמד על סיוג הסבת המחסן כאמור. אך נוכח נוסחו של ההסכם, במתכונת שתוארה, איני מתרשמת כי די בעצם העובדה כי הסבת המחסן לא הופיעה בתשריט כדי ללמד על סיוג ההתחייבות בדבר.

11. לטענת רום ארד, רק לאחר כריתת ההסכם ביצעה בדיקות, מהן גילתה, כי הסבת המחסן אינה אפשרית. בתצהיר העדות הראשית שמסר עו"ד [redacted] סמנכ"ל רום ארד ויועץ משפטי בה בזמנים הרלוונטיים (להלן: "עו"ד [redacted]"), העיד עו"ד [redacted] כי בדיקות מקצועיות אלה נעשו ימים ספורים לאחר כריתת ההסכם (סעיף 27 לתצהיר עו"ד [redacted]). עוד העיד עו"ד [redacted], כי הודיע לה"ה [redacted] כחודש לאחר החתימה על הסכם, כי לא ניתן לבצע את ההסבה (סעיף 28 לתצהיר עו"ד [redacted]). בתצהירו, תירץ עו"ד [redacted] את ביצוע הבדיקות בעיתוי זה, לאחר כריתת ההסכם, בכך שרק במעמד כריתת ההסכם העלו ה"ה [redacted] לראשונה דרישה להסבת המחסן (סעיף 21 לתצהיר עו"ד [redacted]).

אך על אף הגרסה שמסר במקור בתצהירו, אישר עו"ד [redacted] בחקירתו, הלכה למעשה, כי התנהל מו"מ עם ה"ה [redacted] קודם לכריתת ההסכם, וכי במסגרתו דובר אף על הסבת המחסן (עמ' 166, שורות 3 – 7). למעלה מן הצורך, וגם אם אניח, כי אכן הדרישה להסבת המחסן הועלתה על ידי ה"ה [redacted] לראשונה במעמד כריתת ההסכם, הרי שלא ברורה בחירתה של רום ארד להתחייב להסבת המחסן בהסכם, מבלי להבהיר במפורש כי התחייבות זו מותנית בביצוען של בדיקות. זאת בפרט מאחר שאין חולק, כי הסבת המחסן אינה תואמת את היתר הבניה לפרויקט, שהוצא כבר ביום 7.5.12. על כן נדמה כי כבר במעמד כריתת ההסכם ידעה רום ארד כי הסבת המחסן אינה אפשרית. אף לא ברור מהן אותן בדיקות שנדרשה רום ארד לבצע, וכיצד אלו סיפקו לחברה נתונים שלא היו ברשות רום ארד במעמד כריתת ההסכם. עו"ד [redacted] מ[redacted] בעדותו איזה בדיקות ביצע לאחר כריתת ההסכם, ובמה שינו בדיקות אלה את שידע עוד קודם

הודעתה של רום ארד לה"ה [redacted] כי הסבת המחסן אינה אפשרית שבועות בודדים לאחר כרי[redacted] מחזקת הרושם כי רום ארד הציגה מצג חלקי בדבר הסבת המחסן בהסכם, וכי נמנעה מלה[redacted] מפורש את האילוצים להם היא כפופה בעניין, על אף שהיתה מודעת לקיומם.

12. לטענת רום ארד, ה"ה [redacted] היו מודעים היטב כי קיים סיכוי לכך שהסבת המחסן טעונה בדיקה של רום ארד ולקיומה של אפשרות כי לא ניתן יהיה לבצעה. לדבריה, ה"ה [redacted] קנו ביודעין סיכון, בהתקשרם בהסכם במתכונת זו, וכי התנהלותם אינה מתיישבת עם חובת תום הלב במימוש זכות חוזית.

אך לא השתכנעתי מה טענה כי ה"ה [redacted] היו מודעים לאפשרות כי לא ניתן יהיה לבצע את הסבת המחסן. בחקירתו הנגדית אישר [redacted] כי קודם לכריתת ההסכם היה מודע לקיומה של אפשרות של רום ארד לנייד זכויות בניה באופן שיאפשר את הסבת המחסן (עמ' 73, שורה 6), וכי הבין כי קיימת גם האפשרות כי הסבת המחסן לא תיתכן, אף כי הבין כי מרבית הסיכויים הם כי הסבת המחסן תתאפשר (שם, שורה 8). לצד זאת, טען [redacted] כי בעת כריתת ההסכם הניח כי רום ארד השלימה את בדיקת היתכנות הסבת המחסן, ומכאן הניח כי בהתקשרותה בהסכם בנוסחו זה התחייבה רום ארד לדבר שהוא אפשרי מבחינתה (עמ' 74, שורות 12 – 14).

הנחתו זו של [redacted] כי במעמד כריתת ההסכם היה ביכולת רום ארד לבצע את הסבת המחסן עולה בקנה אחד עם נוסח ההסכם, אודותיו הרחבתי לעיל, ממנו משתמע כי אכן הסבת המחסן אינה בגדר אפשרות הטעונה בדיקה גרידא, כי אם התחייבות, הכפופה להוראות החוק ולאילוצים תכנוניים – כיתר ההתחייבויות בהסכם.

ראוי להפנות, בהקשר זה, לאמות המידה להוכחת ידיעה בפועל של קונה כי התחייבות חוזית של המוכרת היא בגדר אפשרות בלבד, כפי שפורטו בפסק הדין שניתן בת"א (שלום ירושלים) 17512/99 *שטרן חיים נ' סאסי קבלני עפר בנין וכבישים (1986) בע"מ*, *בפסקה 5.2.2* (פורסם במאגרים 13.01.2009, להלן: "עניין שטרן"), אליו הפנתה רום ארד. בעניין שטרן נפסק, בנוגע לתחולת הוראת סעיף 12 לחוק המכר, התשכ"ח – 1968, כי יכולתו של הקונה להסתמך על אי התאמה תישלל רק מקום בו היתה לו ידיעה בפועל, קרי ידיעה ממשית, על אי ההתאמה, אשר היא ידיעה קונקרטית, על פגם ספציפי, המודעת לא רק למצב הדירה אלא גם לנורמות החלות על בנייתה. עוד נקבע, כי על המוכר האחריות להפנות את שימת ליבו של הקונה לתקנים ולעובדה כי הדירה נבנתה בניגוד להם. על דרך ההיקש, מקום בו לא הבהירה רום ארד באופן מפורש בהסכם כי הסבת המחסן היא בגדר אפשרות בלבד, זולת על דרך הוראות כלליות לפיהן ההסכם כפוף להוראות החוק ולאילוצים תכנוניים, וכן לא הבהירה מהן הוראות החוק והאילוצים התכנוניים שעשויים לשלול אפשרות זו – אין לייחס להה"ה [redacted] ידיעה בפועל כנטען.

13. רום ארד הפנתה לפסק הדין שניתן בת"א (מחוזי חי') 176-06 *עופר חלמיש נ' חוף הכרמל נופש ותיירות 89 בע"מ* (פורסם במאגרים 17.08.2010, להלן: "עניין חלמיש"). רום ארד טענה כי כפי שנפסק בעניין חלמיש, גם בענייננו ה"ה [redacted] קנו ביודעין סיכון, כאשר עוד טרם חתימתם על ההסכם ידעו כי הסבת המחסן היא בגדר אפשרות בלבד.

אך אין בהפניה זו כדי לשפוך אור על הסוגיה שלפני. בעניין חלמיש, טענו התובעים לביטולם של הסכמים לרכישת שתי דירות בפרויקט בחוף הכרמל בחיפה. הנתבעת, מוכרת הדירות, התחייבה להעמידן לרשות התובעים. אך לצד זאת, הבהירה במפורש בהסכמי המכר, כי התכנון הסביבתי והקמת פרויקט המרינה ועיר הקיט, טרם אושר על ידי רשויות התכנון, וכי אין וודאות כי זה יאושר על ידי רשויות התכנון. בנסיבות אלה,

קבע בית המשפט, כי התובעים רכשו סיכוי כי רשויות התכנון תאשרנה את הפרויקט בלבד, וכי אין להם להלין על הנתבעת על כך שהפרויקט לא אושר בסופו של דבר. עניין חלמיש דווקא תומך בגרסת ה"ה [redacted] זאת מאחר שבניגוד להתנהלות הנתבעת בעניין חלמיש, במקרה שלפני רום ארד לא שיקפה באופן מפורש בהסכם כי הסבת המחסן טעונה אישור, וכי אין וודאות כי תאושר. ההיפך הוא הנכון, רום ארד התחייבה להסבת ההסכם ללא סייג מפורש, למעט הוראות הכלליות לפיהן תניות ההסכם כפופות להוראות הדין ולהנחיית הרשויות המוסמכות. ממילא אין רום ארד יכולה להלין על ה"ה [redacted] שקנו ביודעין סיכון.

טענות רום ארד כי עמדה לה"ה [redacted] האפשרות לביטול הסכם המכר

14. לטענת רום ארד, היא הודיעה לה"ה [redacted] כחודש וחצי בלבד לאחר החתימה על ההסכם, כי הסבת המחסן היא בלתי אפשרית. לדבריה, בשלב זה שילמו ה"ה [redacted] סך של 100,000 ₪ בלבד על חשבון תמורת הדירה, ועמדו בפניהם שתי אפשרויות – לבטל את הסכם המכר ולקבל חזרה את המקדמה ששולמה, באופן שלא יגרם להם כל נזק, או לקיים את ההסכם, בשינויים המתחייבים. רום ארד טענה, כי ה"ה [redacted] בחרו שלא לבטל את הסכם המכר, והיו מעוניינים בקיומו. עוד טענה רום ארד, כי זכות ה"ה [redacted] לקבלת פיצוי במקרה זה נשללת גם מכוח עקרון הקטנת הנזק, שכן לו היו מבטלים את ההסכם עם קבלת העדכון על המניעה החוקית להסבת המחסן – לא היה נגרם להם נזק. אך רום ארד לא הוכיחה כי אכן הוצגה בפני ה"ה [redacted] אפשרות ביטול העסקה כתוצאה מאי הסבת המחסן.

15. הטענה כי הוצעה לה"ה [redacted] האפשרות לביטול ההסכם בשל היעדר אפשרות להסבת המחסן הועלתה לראשונה בתצהיר העדות הראשית מטעם עו"ד [redacted] עו"ד [redacted] העיד בתצהירו, כי כחודש לאחר החתימה על ההסכם, ולאחר בדיקות שערכה רום ארד בעניין, הודיע לה"ה [redacted] כי לא ניתן מבחינה חוקית לבצע את ההסבה, וכי רום ארד תאפשר לה"ה [redacted] לבטל את הסכם המכר מבלי לשאת בסנקציה או בחיוב כלשהו, כך שלאף אחד מהצדדים לא ייגרם נזק בשל ביטול ההסכם (סעיפים 28 – 29 לתצהיר עו"ד [redacted] . אך לא הוצגו כל תימוכין בכתב להודעות הנטענות של עו"ד [redacted] לה"ה [redacted] הן בדבר היעדר חוקיות הסבת המחסן והן בדבר האפשרות לביטול העסקה בידי ה"ה [redacted]

עו"ד [redacted] התקשה להבהיר מתי בדיוק הודיע לה"ה [redacted] על היעדר האפשרות להסבת המחסן ועל האפשרות העומדת להם לביטול ההסכם ולהציג אסמכתא להודעות אלה. בתצהירו טען, כי עדכן את ה"ה [redacted] בדבר כחודש לאחר כריתת ההסכם. אך בחקירתו הנגדית אישר, כי אכן לא הועבר לה"ה [redacted] מסמך כתוב המתעד את עמדת רום ארד לפיה אין אפשרות להסבת המחסן. הוא תירץ הדבר בכך שבשלב זה לא תקשרו הצדדים באמצעות התכתבויות בשל היחסים החבריים ששרו ביניהם (עמ' 148, שורות 5 – 6).

באשר לתיעוד כתוב לאפשרות שהוצגה לה"ה [redacted] לביטול ההסכם – עו"ד [redacted] נשאל בעניין בחקירתו שוב ושוב, אך מסר תשובות מתחמקות ובלתי עקביות. עו"ד [redacted] טען כי ברשותו אסמכתא לכך שהוצגה לה"ה

[redacted] אפשרות לביטול העסקה כאמור (בעמ' 150, שורה 3), אך נמנע מלהציג אסמכתא כנטען, והסתפק בהפניה לפרוטוקול פ גישה עם ה"ה [redacted] מיום 5.8.14 (נספח י"ח לכתב התביעה, למשל בעמ' 150, שורות 5 – 7). מדובר בפרוטוקול שנערך למעלה משמונה חודשים לאחר כריתת ההסכם, בו לא הופיעה כל התייחסות לאפשרות שעמדה להה"ה [redacted] לביטול העסקה, אף כי בפרוטוקול זה תועדה הסכמה מאוחרת של הצדדים בנוגע להסבת המחסן, אודותיה ארחיב להלן. מעבר לכך, לא הציג עו"ד [redacted] כל אסמכתא להצגת האפשרות לביטול העסקה להה"ה [redacted] זולת הפניה כללית לפרוטוקולי הפגישות בין הצדדים (למשל, בעמ' 153, שורות 6, 11).

16. [redacted] מצידו, הכחיש כי נאמר להה"ה [redacted] כי הסבת המחסן אינה חוקית, או כי ה"ה [redacted] זכאים לבטל את ההסכם בגין כך. [redacted] טען, כי רק כחודש וחצי לאחר כריתת ההסכם, נאמר להה"ה [redacted] כי הסבת המחסן אינה אפשרית, וזאת בישיבה מיום 7.1.14, בה נכחו ה"ה [redacted] ועו"ד [redacted] [redacted] הפנה לפרוטוקול הישיבה מיום 7.1.14, בו תיעוד לעניין הסבת המחסן (להלן: "פרוטוקול ינואר"). בפרוטוקול ינואר אין כל אזכור של אי חוקיות הסבת המחסן או של אפשרות לביטול ההסכם בידי ה"ה [redacted] כל שנכתב בפרוטוקול ינואר הוא כי ביצוע ההסבה ייעשה על ידי הדייר, וכי הוצע להה"ה [redacted] זיכוי בידי [redacted] מנהל הפרויקטים בחברה (להלן: "[redacted]") כך שהביצוע ייעשה באמצעות אוריון, כפי [redacted] התנגד להצעה, וכי ה"ה [redacted] התנגדו אף הם לכך. כעולה מלשון הפרוטוקול, לא דובר על אי חוקיות של הסבת המחסן, או על אפשרות לביטול ההסכם. כל שדובר הוא כי ה"ה [redacted] יישאו בהשלמת העבודות וכי יקבלו זיכוי בגין כך מרום ארד. לשון הפרוטוקול תומכת בגרסת ה"ה [redacted] כי אי חוקיות הסבת המחסן וכן אופציית ביטול העסקה כלל לא הועלו על ידי רום ארד במועד זה.

סוגיית אי חוקיות הסבת המחסן לא תועדה גם בפרוטוקולים נוספים של פגישות שהתקיימו בין ה"ה [redacted] לנציגי רום ארד ואוריון. למעשה התיעוד הראשון הכתוב להבהרת רום ארד בדבר אי חוקיות הסבת המחסן הוא בפרוטוקול סיכום פגישה עם ה"ה [redacted] מיום 6.4.13, למעלה מארבעה חודשים לאחר כריתת הה[redacted] בו נכתב: "הובהר ללקוחות כי הסבת המחסן למקלחת לא תבוצע על ידינו וכי הנ"ל מנוגד לחוק" (נספ[redacted] לכתב התביעה).

17. אישוש מסויים לטענת ה"ה [redacted] בעניין ניתן למצוא בגרסת רום ארד עצמה, כפי שפורטה בסיכומי [redacted] ארד בחרה לסטות מהגרסה המקורית שמסר עו"ד [redacted] בתצהירו, הן בנוגע לעיתוי יידוע ה"ה [redacted] אי חוקיות הסבת המחסן והן בנוגע לעצם יידועם של ה"ה [redacted] בדבר האפשרות שעומדת להם לבטל את ההסכם בשל כך.

בעניין ההודעה על אי חוקיות הסבת המחסן - כזכור, בתצהירו טען עו"ד [redacted] כי הודיע להה"ה [redacted] כי הסבת המחסן אינה חוקית "כחודש אחד בלבד לאחר החתימה על הסכם המכר" (סעיף 28 לתצהיר עו"ד [redacted]. אך בסיכומיה טענה רום ארד כי היא הודעה כאמור נמסרה להה"ה [redacted] רק "כחודש וחצי בלבד לאחר החתימה על ההסכם" (סעיף 8 לסיכומי רום ארד). משמע שרום ארד הכירה בכך שרק בפגישה מיום 7.1.14

עודכנו ה"ה [redacted] בעיין הסבת המחסן, כפי טענת ה"ה [redacted] אך אזכיר, כי פרוטוקול ינואר המתעד את האמור בפגישה זו אינו תומך בגרסת רום ארד, ולא ניתן ללמוד ממנו על יידוע ה"ה [redacted] על אי חוקיות הסבת המחסן.

באשר להודעה בדבר האפשרות שעומדת לה"ה [redacted] לבטל את ההסכם בגין כך – כזכור, בתצהירו טען עו"ד [redacted] כי הודיע לה"ה [redacted] כי עומדת להם האפשרות לביטול העסקה (סעיף 29 לתצהיר עו"ד [redacted] . אך בסיכומיה שינתה רום ארד גרסתה גם בעניין זה, והסתפקה בטענה כי משהודיעה רום ארד להה"ה [redacted] כי היא מנועה מבחינה חוקית לבצע את הסבת המחסן, "עמדו בפני התובעים שתי אפשרויות: לבטל את ההסכם ולקבל חזרה את המקדמה ששולמה (באופן שלא יגרם להם נזק) או לקיים את ההסכם בשינויים המתחייבים כתוצאה מהוראות החוק" (סעיף 8 לסיכומי רום ארד). משמע שה"ה [redacted] לא עודכנו באופן מפורש באפשרות לביטול ההסכם, רק עמדה להם האפשרות לבטלו מעצם ידיעתם כי היא לא תוכל לבצע את הסבת המחסן (ראו גם בנוסח סעיף 10 לסיכומי רום ארד). שינויי גרסה אלה מחזקים את טענות ה"ה [redacted] בנוגע לעיתוי יידועם בדבר אי חוקיות הסבת המחסן ובנוגע לאפשרות לביטול העסקה.

18. למעלה מן הצורך, לא השתכנעתי מהטענה כי במקרה בו בוחר לקוח שלא לבטל הסכם, חרף הפרתו, מנוע הוא מלתבוע פיצוי בגין ההפרה. אף אין בידי לקבל את הטענה כי בנסיבות אלה נשללת מהלקוח הזכות לקבלת פיצוי מכוח עקרון הקטנת הנזק. הדבר מנוגד לפשט לשון הוראות סעיפים 2, 7 ו- 10 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, לפיהן משהופר חוזה, זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וכן זכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות, או במקומן.

כתימוכין לטענתה הפנתה רום ארד לפסק הדין שניתן בת"א (מחוזי ת"א) 1029-09-09 *קד-קו בניין פיתוח וכבישים בע"מ נ' מבני גאיה יזום והשקעות בע"מ* (פורסם במאגרים 04.02.2015). אך אין המשל דומה לנמשל. בעניין זה בחרו הנתבעים שלא לבטל הסכמי מכר, ולא השיבו תמורה שקיבלו על פי אות[redacted] על כן נפסק, כי מדובר בהסכם שרירים וקיימים וכי הנתבעים אינם יכולים לתבוע זכויות כלשהן התקשרות שבוטלו בהסכמי המכר (פסקה 40 לפסק הדין). אין בכך כדי ללמד על כך שה"ה [redacted] יכולים לתבוע פיצוי בשל הפרת ההסכם, אחר שבחרו שלא לבטלו. עוד הפנתה רום ארד בהק חלמיש. ההפניה לעניין חלמיש נעשתה כלאחר יד, ולא ברור היה מסיכומי רום ארד על איזו מ הדין היא מבקשת להסתמך. ניתן לשער כי רום ארד ביקשה להיבנות מהקביעה לפיה ניתן בנסיבות המקרה שם, כי התובעים יתבעו את ביטול הסכמי המכר זה מכבר. אך התובעים נמנעו מלעשות כן, שילמו את מלוא התמורה בגין הדירות ולא נקטו בצעדים משמעותיים לביטול ההסכמים כאמור, והדבר מונע מהם את האפשרות להשתחרר מהסכמי המכר כעת (פסקה 29 לפסק הדין). אין בין כך לבין המחלוקת בענייננו דבר.

19. סיכומם של דברים, רום ארד אכן התחייבה במסגרת הסכם המכר לביצוע הסבת המחסן. רום ארד לא הוכיחה כי בעת שהודיעה להה"ה [redacted] כי הסבת המחסן אינה אפשרית העמידה בפניהם את האפשרות

לביטול הסכם המכר, ואף לא הוכיחה כי די היה בעצם העמדת האפשרות לביטול הסכם המכר כדי לשלול מה"ה [redacted] זכות לפיצוי.

על אף האמור, ונוכח הסכמות מאוחרות שהושגו בין הצדדים, אין מקום לפצות את ה"ה [redacted] בגין הסבת המחסן, כפי שאפרט להלן.

<u>ההסכמות שהתגבשו בין הצדדים בנוגע להסבת המחסן</u>

20. חרף התחייבותה החוזית של רום ארד להסבת המחסן, אודותיה הרחבתי לעיל, הגיעו הצדדים להסכמות בעניין הסבתו, וזאת לסילוק טענות הצדדים בעניין, כמתועד בפרוטוקולי פגישות שהתקיימו בין הצדדים בימים 28.1.14 ו- 5.8.14, כדלקמן:

פרוטוקול הפגישה מיום 28.1.14

21. ביום 28.1.14 נערכה פגישה בין ה"ה [redacted] לבין נציגי רום ארד ואוריון. בפרוטוקול הפגישה מיום 28.1.14 תועד הסיכום הבא בנוגע להסבת המחסן (שורות 1 – 2 לטבלה, בנושא "שינוי מחסן לחדר רחצה"):

> "בפגישה בתאריך 28.1.2014 – סוכם כי [redacted] ימצא קבלן גמר שיבצע את עבודות הגמר הסופיים בדירה כולל שארית העבודות שיתבקשו להסבת המחסן באופן סופי לחדר רחצה. סוכם בין [redacted] ובין [redacted] כי התשלום עבור סיום העבודות ישולם על ידי היזם – קבוצת חנן מור."

בהמשך הפרוטוקול פורט שוב הסיכום, כדלקמן (שורה 14 לטבלה, בנושא "אי התאמות בין המפרטף תכנית המכירה והבטחות במעמד רכישה"):

> "...
> 8. הובטח לדיירים כי ביצוע השינוי ממחסן לח. רחצה יבוצע במלואו.-בפגישה בתאריך 28.1.2014 – סוכם כי [redacted] יבצע את השינוי לאחר מסירה על ידי קבלן גמר והתשלום לקבלן יבוצע על ידי קבוצת חנן מור."

לצד זאת תועדה דרישת ה"ה [redacted] להוספה במסמך הזמנת שינויים מהיזם של ההבהרה כי רום ארד אחראית לכל היבטי הבניה וביצוע העבודות שהוזמנו עד למסירת הדירה – על כך הבהיר עו"ד [redacted] כי מסמכים אלה אינם ניתנים לשינוי, כדלקמן (שורה 5 לטבלה, בנושא "מסמך הזמנת שינויי (כך במקור) מהיזם"):

> "להלן דרישת הדיירים לשינויים במסמך זה:

...

7. יש לחדד ולהוסיף כי ברור שהחברה אחראית על כל הבטי הבניה וביצוע השינויים וכל העבודות שהוזמנו כולל אחריות לנושא גנבה עד מסירת הדירה לרשותנו.

בפגישה בתאריך 28.1.2014 – הובהר על ידי [redacted] כי מסמכי (כך במקור) אלו לא ניתנים לשינוי."

22. לטענת רום ארד, מפרוטוקול זה עולה הסכמה כי הסבת המחסן תתבצע על ידי ה"ה [redacted] לאחר מסירת הדירה לחזקתם, באמצעות קבלן מטעמם, כאשר רום ארד אחראית כלפי ה"ה [redacted] בכל הנוגע להיבטי הבניה רק עד למועד ביצוע הסבת המחסן או עד למועד מסירת הדירה לחזקת ה"ה [redacted] לצורך ביצוע עבודות ההסבה כאמור.

אכן מנוסח פרוטוקול הפגישה מיום 28.1.14 עולה, כי ה"ה [redacted] הסכימו לקחת על עצמם את האחריות למצוא קבלן גמר לביצוע העבודות להסבת המחסן, וזאת במימונה של רום ארד. עם זאת, אין בסיכום המתועד בפרוטוקול זה כדי ללמד על כך שהצדדים הסכימו כי רום ארד מסירה את אחריותה להסבת המחסן. אף אין בפרוטוקול תיעוד כלשהו לויתור של ה"ה [redacted] על טענות כלפי רום ארד בקשר עם הסבת המחסן כאמור.

פרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14

23. ביום 5.8.14 נערכה פגישה בין ה"ה [redacted] עורך דינם של ה"ה [redacted] – עו"ד הרוש, נציגי רום ארד ואוריון. בפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 , שנערך במעמד ב"כ ה"ה [redacted] כאמור, תועד סיכום של שורה של סוגיות השנויות במחלוקת, בהן גם סוגיית המחסן. בהתאם לסיכום, לקחו על עצמם ה"ה [redacted] את ביצוע הסבת המחסן, וזאת כאשר עלות הסבת המחסן ממומנת על ידי רום ארד, כדלקמן (שורה 9 לטבלה, בנושא "מחסן דירתי"):

"**<u>מחסן דירתי</u>**

- הדייר יבצע את המחסן לאחר קבלן (כך במקור) טופס 5
- הדייר יבצע את המחסן עם קבלן הגמרים של הפרויקט. אוריון תדאג לסגירת מחיר אל מול קבלן הגמרים. הדייר יחתום חוזה אל מול קבלן הגמרים."

לצד סוגיית הסבת המחסן התחייבה רום ארד כלפי ה"ה [redacted] במסגרת פרוטוקול זה לביצוע שורה של תוספות והתאמות.

בתחתית הפרוטוקול מיום זה נכתב, כדלקמן (שורה 15):

"סיכום זה מהווה סך סופי של טענות הצדדים כלפי משנהו וכי במקרה של סתירה בין האמור בנספח זה להסכם המכר על נספחיו יגבור האמור לעיל. הנ"ל מהווה הבהרה ולא תוספת למפרט המכר."

מלשון פרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 עולה, אם כן, כי הצדדים הגיעו להסכמות סופיות ביחס להסבת המחסן, לפיהן ה"ה [redacted] יבצעו את ההסבה בעצמם, בהתקשרות ישירה מול קבלן חיצוני, כאשר אחריותה היחידה של רום ארד הסתכמה בתשלום עלויות ההסבה, וכאשר הצדדים הסכימו כי יש בסיכום זה משום "סך סופי של טענות הצדדים", כמפורט לעיל.

24. חיזוק לרושם כי אכן הצדדים ראו בסיכום המתועד בפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 כסיכום לסילוק מחל וקות הצדדים ניתן למצוא במכתבו של עו"ד אריק הרוש, ב"כ ה"ר [redacted] מיום 14.9.14, שהופנה לעו"ד [redacted] במכתב זה קבל עו"ד הרוש על אי התקדמות העבודות בדירה, אך ציין בפתח דבריו, כי הסיכום מיום 5.8.14 נועד ליישב את מלוא מחלוקות הצדדים, ובלשון עו"ד הרוש (סעיף 1 למכתב):

"בהמשך למפגש אותו ערכנו במשרדך בנוכחותי ובנוכחות מרשי ונציג מורשה מטעם החברה סוכמו הנושאים אשר בגינם הינו אמורים לסגור את כל הפערים בינינו, אך מאז המפגש חלף מעל חודש ועשרה ימים וטרם נעשתה כל פעולה בדירה, אדגיש כי האיחור במועד המסירה עליו הסכמנו (תוספת של 120 יום מיום המסירה המקורי של הדירה) היה רק לשם קידום הנושאים עליהם הסכמנו, ובשל העובדה שאתם הבהרתם כי נחוצה לכם עבודה רבה בדירה."

משמע שה"ה [redacted] עצמם הבינו, בעודם מיוצגים, כי הסיכום שהושג נועד "לסגירת כל הפערים הצדדים, כלשון עו"ד הרוש.

25. ה"ה [redacted] לא סתרו הרושם בדבר הסיכום הסופי אליו הגיעו הצדדים ביום 5.8.14, ואף איששו רוש

ה"ה [redacted] טענו, כי ניתן לראות בכל פרוטוקול והתכתבות בין הצדדים את התנגדותם להצעת רום ארד לבצע בעצמם את הסבת המחסן. אכן, בפרוטוקולים שקדמו לפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 ניכרת הסתייגותם של ה"ה [redacted] מההצעה לביצוע הסבת המחסן בעצמם. אך אין אלה פני הדברים ביחס לפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14, כמצוטט לעיל.

ביחס לפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 טענו ה"ה [redacted] בכלליות ובאגביות כי רום ארד העלתה במסגרת פרוטוקול זה את נושא הסבת המחסן "וזאת לאחר שהתובעים התנגדו לקבל את המתווה המוצע בכל פגישה בה נערך פרוטוקול" כלשונם (סעיף 3 לסיכומי התובעים, בעמ' 4). אך טענה כללית זו, המפנה להתנגדויות

קודמות של ה"ה [redacted] מתעלמת מפשט לשון פרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14, ומהסיכום שהושג בו, בעוד ה"ה [redacted] מיוצגים בידי עו"ד.

26. בהמשך סיכומיהם טענו ה"ה [redacted] כי רום ארד הפעילה עליהם מניפולציות ועשתה הכל על מנת לגלגל האחריות לעניין הסבת המחסן עליהם או על קבלן חיצוני אחר, ממנו התנערה. הם גם טענו, כי כחלק ממניפולציות אלה הציעה להם רום ארד לבצע את הסבת המחסן לאחר קבלת טופס 5, לצד הצעות אחרות בהן הוצאת פרוטוקול מסירת דירה פיקטיבי, פיטורי אוריון מביצוע עבודות בדירה, הקפאת העבודות בדירה, העברת כספים דרך ה"ה [redacted] לקבלן הביצוע וכן 120 ימי גרייס לביצוע העבודות. עוד טענו, כי רום ארד נקטה בגישה אגרסיבית של עיכוב הבניה על מנת להפעיל על ה"ה [redacted] לחץ, ולכפות עליהם את רצונה. לדברי ה"ה [redacted] מלחמת ההתשה של רום ארד לא השאירה להם ברירה, למרות התנגדותם, שכן הם ידעו כי ללא שיתוף פעולה עם רום ארד לא יוכלו לקבל את החזקה בדירה בעתיד הנראה לעין (סעיף 3 לסיכומי התובעים, בעמ' 5). הם הבינו, כי על מנת למזער נזקים עליהם להיכנע "לדרך בה הנתבעת מסכימה כביכול לבצע את התחייבותה" (סעיף 3 לסיכומי התובעים, בעמ' 6).

מטענותיהם אלה של ה"ה [redacted] משתמע , כי ה"ה [redacted] אכן אישרו, הלכה למעשה, כי הושגו הסכמות עם רום ארד, לסילוק מלוא טענות הצדדים האחד כלפי משנהו. אך הם טענו כי הסכמות אלה נבעו ממניפולציות וממלחמת התשה מצד רום ארד, שלא הותירה להם ברירה אלא להסכים כאמור.

לא התרשמתי כי הסיכום שהושג נכפה בצורה כלשהי על ה"ה [redacted] כי ה"ה [redacted] לא היו מודעים למשמעותו, או כי הסיכום לא היה הוגן כלפי ה"ה [redacted] ה"ה [redacted] היו מיוצגים במעמד הפגי[redacted] הסיכום נעתרה רום ארד לשורה של דרישות מצד ה"ה [redacted] וממילא לא ניתן לקבוע כי הסכמ[redacted] להסדרת הסבת המחסן בעצמם – לא היתה סבירה בנסיבות אלה.

מעבר לכך ה"ה [redacted] הודו בעצמם בסיכומיהם, כי בעוד הם ביטאו השגות ביחס לפרוטוקולים [redacted] פגישות עם רום ארד, הם בחרו שלא להשיג על פרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14. הם טענו, כי הפרוטוקולים "למעט מקרה אחד טכני" (סעיף 3, בעמ' 5 לסיכומי התובעים). טענה חדשה זו, [redacted] לא השיגו על הפרוטוקול מיום 5.8.14 מטעמים טכניים, לא הועלתה עד לשלב הסיכומים, ועל כן אין להידרש לה. ומכל מקום, הטענה הועלתה כלאחר יד, ללא הסבר מדוע דווקא על פרוטוקול זה לא הוגשה השגה מטעמם. על כן אין בטענה זו די.

בשלב מסויים בסיכומיהם, טענו ה"ה [redacted] כי רום ארד "לא הביאה בדל ראיה לכך" שהם אכן ביצעו בפועל את הסבת המחסן. בסיכומי התשובה מטעמם הרחיבו ה"ה [redacted] וטענו, כי עובדי רום ארד הם שביצעו בפועל את עבודות ההסבה. אך גם אם אניח כי בפועל בוצעו עבודות ההסבה בידי עובדי רום ארד, אין בכך כדי להפריך הרושם לפיה ה"ה [redacted] הסכימו כי סוגיית הסבת המחסן היא באחריותם, אף כי במימון רום ארד, וכי ויתרו על טענותיהם כלפי רום ארד בעניין הסבת המחסן.

27. סיכומם של דברים, על אף התחייבותה החוזית של רום ארד לביצוע הסבת המחסן, הודיעה רום ארד לה"ה [redacted] לאחר כריתת הסכם המכר, כי אין באפשרותה לעשות כן. לאחר פגישות ותכתובות מרובות, בפגישה מיום 5.8.14, בה היו ה"ה מיוצגים בידי עו"ד, הושג סיכום ביחס לשורה של עניינים שהיו שנויים במחלוקת, וזאת לסילוק כל טענות הצדדים. בין היתר סוכם, כי ה"ה [redacted] ייקחו על עצמם את הסדרת המחסן, במימון רום ארד. אחר שהושג הסיכום, מנועים ה"ה [redacted] מהעלאת טענות בקשר להתחייבות רום ארד להסבת המחסן.

<u>גובה הפיצוי לו זכאים ה"ה [redacted] בגין סוגיית הסבת המחסן</u>

28. בהתאם לסיכום שהושג בפגישה מיום 5.8.14 הוסב המחסן לחדר רחצה בידי ה"ה [redacted] אך זאת ללא קבלת היתר. במילים אחרות, ה"ה [redacted] בחרו ביוזמתם לבצע בניה ללא היתר, במימון רום ארד, וכעת עותרים לפיצוי בגין המצב הקיים, בו הוסב המחסן בפועל, אך ללא היתר.

מהנדס הבניין ושמאי המקרקע[redacted] (להלן: "המהנדס[redacted]") מונה כמומחה מטעם בית המשפט לחוות דעתו ביחס להשלכות הכספיות של המצב הקיים, לפיו בוצעה הסבת המחסן ללא היתר כאמור (בסעיף 5 לחוות דעת [redacted].

המהנדס [redacted] התייחס בחוות דעתו לשני תרחישים אפשריים. התרחיש הראשון הוא כי הועדה המקומית תאשר את הסבת המחסן, בכפוף להגשת תכנית בקשה להיתר. התרחיש השני הוא כי הועדה המקומית תסרב לאשר את הסבת המחסן ותדרוש השבת המצב לקדמותו בהתאם לתכנית הקיימת.

במקרה בו הועדה המקומית תאשר את הסבת המחסן, אמד המהנדס [redacted] את ההשלכות הכספיות בסך של 54,000 ₪ כולל מע"מ, וזאת בגין עלות הכנת תכנית הגשה לשינוי יעוד המחסן לחדר רחצה (בסך של 30,000 ₪ בתוספת מע"מ) ובגין היטל השבחה בסך של 18,624 ₪. בחקירתו הבהיר המהנדס [redacted] כי לשם אישור הסבת המחסן נדרש לעתור בבקשה להקלה לעירייה, המוגשת על ידי בעל הנכס (עמ' 44, שורות 9 – 11, 21).

המהנדס [redacted] בחן ודחה את האפשרות שהועלתה על ידי האדריכל [redacted] מטעם ה"ה [redacted] לפיה כתנאי לקבלת היתר להסבת המחסן נדרש כי תבוצע פעולה של פירוק חדר הרחצה ובנייתו מחדש. לדבריו, אפשרות זו "אינה מעשית ובסבירות נמוכה", ומטעם זה בחר שלא להתייחס אליה כלל.

במקרה בו הועדה המקומית לא תאשר את הסבת המחסן ותדרוש את השבת המצב לקדמותו בהתאם לתכנית הקיימת, העריך המהנדס [redacted] את עלות הסבת חדר הרחצה למחסן בסך כולל של 73,000 ₪ (סך של 20,000 ₪ בגין פירוק חדר הרחצה ופינוי הפסולת, סך של 20,000 ₪ בגין בניית מחסן וסך של 33,000 ₪

בגין הקמת חדר רחצה במקום אחר בדירה). בנוסף, העריך המהנדס [redacted] את ירידת הערך בגין הסבת חדר הרחצה למחסן בסך של 132,225 ₪. לפיכך ההשלכות הכספיות של התרחיש השני מסתכמות בסך של 205,225 ₪ כולל מע"מ.

29. לטענת רום ארד, לכל היותר זכאים ה"ה [redacted] לפיצוי בהתאם לתרחיש הראשון – עלות הכשרת הסבת המחסן (זאת בכפוף להכחשתה העקרונית את עצם זכאותם לפיצוי כלשהו). רום ארד הפנתה לטענותיהם של ה"ה [redacted] כי הם האמינו שהכשרת המחסן אפשרית, ואף עתרו בבקשה לצו מניעה זמני בגדרו של הליך זה, למניעת רישום הבית המשותף על מנת שיהיו יכולים להכשיר את ההסבה ביתר קלות. כמו כן הפנתה רום ארד לדברי המהנדס [redacted] בחקירתו, כי בקשה להקלה היא הליך מאוד מקובל (עמ' 43, שורה 13).

רום ארד קבלה על כך שה"ה [redacted] לא פעלו עד היום להקלה שתכשיר את ההסבה, ולו על מנת להקטין את נזקיהם הנטענים, וכן כי עד למועד זה לא טרחו לפרק את ההסבה, על אף ידיעתם כי הם עוברים עבירת שימוש. היא סברה, כי ה"ה [redacted] ידעו כי באפשרותם להכשיר את הסבת המחסן בקלות, אך ביכרו להמתין לסוף ההליך כדי לא לפגוע בסיכוייהם להוציא מרום ארד כספים בגין ירידת ערך – שתתבטל מייד עם ההכשרה. היא טענה כי התנהלות ה"ה [redacted] עולה כדי חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי בית משפט.

אני מקבלת את טענותיה של רום ארד, כי ה"ה [redacted] אינם זכאים לפיצוי בהתאם לתרחיש השני, אף כי מתרשמת כי ה"ה [redacted] אכן זכאים לפיצוי בהתאם לתרחיש הראשון.

30. ה"ה [redacted] בחרו, משום מה, לבצע את הסבת המחסן בפועל, מבלי שהתקבל לכך היתר. בחירתם זו מנוגדת להוראות הדין, אינה ניתנת להצדקה, ולבטח שאין להטיל על רום ארד את השלכותיה, נוכח הסיכום שהושג בין הצדדים לפיו ה"ה [redacted] ייקחו על עצמם את ביצועה של הסבת המחסן כאמור.

עצם הבחירה של ה"ה [redacted] לבצע את הסבת המחסן, אף אם ללא היתר, מקפלת בחובה את ההנחה כי הסבת המחסן ניתנת להכשרה. אין כל הסבר הגיוני אחר להשקעת המשאבים בהסבת מחסן, אשר הכשרתה אינה אפשרית.

בכפוף לאמור, מאחר שרום ארד התחייבה לקחת על עצמה את עלות הסדרת הסבת המחסן, מאחר שבכל מקרה פעולת הסבת המחסן היתה טעונה אישור, בהיותה מנוגדת להיתר, ובהיעדר ראיות לעלות בקשה לאישור, קודם להסבת המחסן, ומאחר שבכל מקרה היה על רום ארד לשאת בהיטל ההשבחה בגין כך, הרי שיש לחייב את רום ארד בפיצוי ה"ה [redacted] בהתאם לתרחיש הראשון, בסך כולל של 54,000 ₪ כאמור.

31. עם זאת, אין מקום לחייב את רום ארד בפיצוי ה"ה [redacted] בהתאם לתרחיש השני.

אין הצדקה להטיל על רום ארד את עלות הסבת המחסן לחדר רחצה, במקרה בו לא תוכשר הסבת המחסן. זאת מאחר שרום ארד אינה אחראית לבחירתם של ה"ה [redacted] לביצוע העבודות קודם לקבלת היתר כאמור, אחר שהושג סיכום בין הצדדים בעניין.

אף אין הצדקה לפסוק לטובתם של ה"ה [redacted] פיצוי בגין ירידת הערך בהתאם לתרחיש השני, במקרה בו לא תוכשר הסבת המחסן. כפי שהרחבתי לעיל, בהתאם לסיכום מיום 5.8.14, לקחו על עצמם ה"ה [redacted] את ביצוע הסבת המחסן והסדרתה, וזאת במימון רום ארד. סיכום זה היה לסילוק כל טענות הצדדים. הצדדים לא מצאו לסייג הסכמותיהם בכך שבמידה שהסבת המחסן אינה אפשרית יפוצו ה"ה [redacted] בפיצוי כלשהו על ידי רום ארד בגין כך. סיכום זה שומט הקרקע תחת טענתם של ה"ה [redacted] לזכאות לפיצוי בגין ירידת ערך כעת.

32. מעבר לכך, וכאמור, בהתאם לסיכום הסדרת הכשרת המחסן נותרה באחריות ה"ה [redacted] דבר לא מנע מה"ה [redacted] לנקוט בהליכים להסדרת הכשרת הסבת המחסן קודם לביצוע עבודות הבניה, ולמצער – סמוך לאחר ביצוען. אך ה"ה [redacted] בחרו לבצע את הסבת המחסן בפועל, מתוך תקווה כי ניתן יהיה להכשירה, ולצד זאת נקטו בפעולות מעשיות להכשרת הסבת המחסן, ואף תבעו במסגרת תביעה זו פיצוי בגין ירידת ערך, תחת ההנחה כי הכשרת המחסן אינה אפשרית.

[redacted] מדובר בניסיון לאחוז בחבל בשני קצותיו – לבצע הסבת מחסן ללא היתר וליהנות מיתרונותיה – מחד אך לתבוע פיצוי בגין ירידת ערך כאילו הסבת המחסן אינה אפשרית – מאידך גיסא. זאת מבלי לב מהלך להכשרת ההסבה שכבר נעשתה – מהלך שבאחריות ה"ה [redacted] לבצע.

[redacted] שונים היו פני הדברים לו היו ה"ה [redacted] נמנעים מביצוע עבודות הסבת המחסן עד למיצוי בדיקת היתי התכנונית של מהלך זה, כנדרש על פי חוק, או למצער – לו היו עותרים ה"ה [redacted] בבקשת הקלה עוד להכרעה בתיק זה. אז היתה המציאות מתבהרת, וניתן היה לקבוע בפסקנות האם הסבת המחסן אפשרית אם לאו. אך ה"ה [redacted] בחרו להותיר סוגייה זו ללא הכרעה. התנהלות זו אינה עולה בקנה אחד עם עקרון חובת הקטנת הנזק, לו כפופים ה"ה [redacted] אינה מוצדקת ואין להכשירה (ת"א (שלום תל אביב-יפו) 65842/01 *בטאט שאול נ' חב' משאבות רם בע"מ* (פורסם במאגרים 08.01.2004)

33. מאחר שהכרעתי, כי ה"ה [redacted] אינם זכאים לפיצוי בהתאם לתרחיש השני מתייתרת הכרעה בטענת רום ארד, כי ההשלכות הכספיות של התרחיש השני מסתכמות בסך של 88,265 ₪ בלבד, ולא כפי שקבע המהנדס [redacted]

למעלה מן הצורך אבהיר, כי לא השתכנעתי כי קיימת הצדקה לסטייה משמעותית מקביעותיו של המהנדס [redacted] אחר שלא הוכחה טעות בולטת בחוות דעתו, ובהתאם לכלל המעוגן בהלכה הפסוקה, לפיו בית המשפט יאמץ את חוות הדעת של המומחה המקצועי אותו מינה, זולת אם תוכח טעות בולטת בה (ראו ע"א

2099/08 *עיריית אשקלון נ' תשלו"ז השקעות והחזקות בע"מ* (פורסם במאגרים 28.10.10)), למעט לעניין יריד‍ת הערך.

34. ככל שהדברים נוגעים לעלויות ביטול ההסבה, לא התרשמתי כי קביעותיו של המהנדס [redacted] היו בלתי סבירות או בלתי מבוססות, ואין די בקביעות שבחוות דעת המומחה מטעם רום ארד, שכללו תמחור בתאם למחירון דקל של עבודות אלה, כדי להפריכן.

זאת בפרט מאחר שחוות הדעת של השמאי [redacted] מטעם רום ארד הוגשה לאחר הגשת חוות דעתו של המהנדס [redacted] כך שממילא לא ניתנה למהנדס [redacted] ההזדמנות להתייחס אליה באופן מסודר. כאשר עומת המהנדס [redacted] עם קבי עותיו של השמא[redacted] בחקירתו הבהיר, כי אינו יכול להתייחס לקביעות אלה במעמד החקירה מבלי לבאר מה עומד בבסיס חוות הדעת (עמ' 47, שורות 20 – 22). הוא גם הבהיר כי האומדן שניתן בחוות הדעת הוא בהתאם לסדרי הגודל המקובלים לעבודות כגון דא (עמ' 48, שורה 24, עמ' 49, שורה 1).

עם זאת, ככל שהדברים נוגעים ליריד‍ת הערך, אישר המהנדס [redacted] בחקירתו, כי יש להפחית מהסכום שקבע בגין יריד‍ת הערך סך של 20,000 ₪, בגין שווי ערך המחסן שיתוסף לדירה כתוצאה מביטול ההסבה (עמ' 55, שורה 11). על כן לו היה מקום לפיצויים של ה"ה [redacted] בהתאם לתרחיש השני, היה להפחית מהסכום שנקבע את הסך של 20,000 ₪ כאמור.

[redacted]

אך איני מקבלת את טענותיה של רום ארד כי יש להפחית מקביעת המהנדס [redacted] סך של 00 יריד‍ת ערך פונקציונאלית. המהנדס [redacted] ביאר בחקירתו, כי יריד‍ת הערך הפונקציונאלית כ מכך שבמקרה של ביטול הסבת המחסן ימוקם חדר הרחצה במרחק של 10 מ"ר מחדר ההורים, הנוכחי. הוא גם הבהיר, כי אין מיקום קרוב יותר לחדר השינה (עמ' 40, שורות 23 – 24, עמ' 41 3, 6 – 7). הסבר זה לא נסתר בידי רום ארד, ואני מוצאת לקבלו. רום ארד טענה אמנם כי בתכני היה חדר הרחצה צמוד לחדר הורים, אך ה"ה [redacted] ביטלו אותו על מנת להגדיל את חדר ההורים. ברם לא הופרכה קביעת המהנדס [redacted] כי בהתאם לתכנית הקיימת לא ניתן למקם את חדר הרחצה בצמידות לחדר ההורים, וב"כ רום ארד התקשתה להצביע על מיקום חלופי לחדר הרחצה כנטען (עמ' 53, שורות 19 – 20).

35. גם ה"ה [redacted] העלו טענות בנודע לקביעותיו של המהנדס [redacted] במסגרת התרחיש השני. לדבריהם, התייחסות המהנדס [redacted] ליריד‍ת ערך על פי התרחיש השני היא חשבונאית בלבד, סוכמת את עלות התיקונים גרידא, ומתעלמת ממאפיינים ספציפיים, כגון מיקום חדר ההורים החדש, ריהוט התואם את מידות חדר השינה, היות חדר השינה מפואר ויוקרתי ופונה לשמורת טבע באופן בו הנוף לא יכול להיחסם בבנייה. ה"ה [redacted] טענו, כי שגה המהנדס [redacted] כשלא לקח מרכיבים אלה בחשבון באמדן יריד‍ת הערך. איני מקבלת טענות אלה.

המהנדס [redacted] הבהיר בחקירתו הנגדית, כי באמדן ירידת הערך התייחס אך ורק לפן התכנוני של הפיכת שטח שירות על פי תכניות הבניה לשטח עיקרי. הוא הבהיר, כי בבחירת ה"ה [redacted] להקדים ולבצע את הסבת המחסן ללא היתר נלקח סיכון, שאין לחשבו באמדן ירידת הערך (עמ' 23, שורות 14 – 19). אכן, משלקחו על עצמם ה"ה [redacted] לבצע את הסבת המחסן בעצמם בהתאם לסיכום שהושג, ביודעם כי ההסבה מנוגדת להיתר, ידעו ה"ה [redacted] כי נכון למועד ביצוע ההסבה לא היתה אפשרות מעשית למיקום חדר הרחצה במקום בו ביקשו למקמו. בכל זאת הסכימו ה"ה [redacted] לבצע בעצמם את ההסבה במימון רום ארד, וזאת לסילוק טענותיהם בעניין.

אחר שהושג סיכום זה, וכפי שהבהרתי לעיל, אין מקום לפצותם בגין ירידת ערך כמכלול, ובכלל זה בגין אבדן המיקום הייחודי של חדר הרחצה – יתרון שלא היה בידיהם לכתחילה. באשר לטענותיהם של ה"ה [redacted] בנוגע לירידת ערך בגין ריהוט התואם את מידות חדר השינה – פיצוי בגין ריהוט אינו פיצוי בגין ירידת ערך, ומכל מקום טענותיהם של ה"ה [redacted] בדבר אבדן ריהוט מותאם למידותיו של חדר השינה נטענו כלאחר יד, ללא פירוט או תימוכין בחוות דעת שבמומחיות, ועל כן אין מקום לפצותם בגין כך.

36. לסיכום, יש לחייב רום ארד בפיצוי ה"ה [redacted] בסך של 54,000 ₪ בגין התרחיש הראשון, אך אין לחייבה בפיצויים בהתאם לתרחיש השני.

<u>איחור במסירת הדירה</u>

37. בהתאם להסכם, אמורה היתה הדירה להימסר לה"ה [redacted] ביום 30.6.14 (להלן: "מועד המסירה החוזי"). לטענת ה"ה [redacted] רק באמצע חודש אוגוסט 2015, כארבעה עשר חודשים לאחר מועד המסירה החוזי, נכנסו בפועל לדירה. על כן טענו ה"ה [redacted] כי יש לפצותם בפיצוי בגין איחור במסירה בסך של 234,000 ₪. איני מקבלת טענתם זו.

הסיכום בדבר איחור במסירה

38. פרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14, אודותיו הרחבתי לעיל, נערך במעמד ה"ה [redacted] ובא כוחם. הסיכום שתועד בפרוטוקול זה הוא לסילוק טענות כל אחד מהצדדים כלפי משנהו. במסגרת אותו סיכום, הסכימו הצדדים כי ה"ה [redacted] יאשרו איחור במסירה של 120 ימי עבודה, כדלקמן (שורה 14 לטבלה, תחת הכותרת: "חתימה על איחור במסירה"):

"בזמן חתימה על החשבון הדייר יחתום על איחור במסירה של 120 ימ"ע"

בהתאם, חתמה [redacted] על חשבון שינויים מיום 14.8.14, בתחתיתו נכתב: "בעקבות שינויים אלו מסירת הדירה תתעכב ב-120 ימי עבודה" (וכן נוסף בכתב יד: "מיום חתימה על הסכם זה", להלן: "חשבון השינויים").

מהסיכום שבפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 ומחשבון השינויים עולה, אם כן, כי לכל הפחות ניתנה הסכמה של ה"ה [redacted] לאיחור של 120 ימי עבודה ממועד המסירה החוזי, זאת אף אם אתעלם מהתוספת בכתב יד ע"ג חשבון השינויים.

39. לטענת ה"ה [redacted] ההסכמה על איחור של 120 ימי עבודה ממועד המסירה החוזי היתה מחווה מצידו של [redacted] כאשר למעשה לא היתה הצדקה לאיחור זה. הוא אף טען, כי ביקש מעורך דינו כי הסיכום בעניין יבוטל, ובלשונו (עמ' 108, שורות 23 – 24, עמ' 109, שורות 1 – 4, 6): "היה, היה ברור לכולם שבגדול ה-120 יום זה איזושהי ג'סטה שלי על האיחור, לא על כמות העבודות, כמות העבודות שאני הייתי מחויב בגינם קריא שינויים היו על סכומים מאוד מאוד קטנים שהצדיקו אולי שבוע ימים, אולי שבוע ימים מהשינויים שלי, כך שה-120 יום זה איזושהי ג'סטה שלי ליזם על האיחור שלו, משלא עבדו חודש ימים, ואפילו יותר מחודש, אז ביקשתי שהעורך דין שלי יבטל את ההבנה הזאתי כי מסתבר ... כי מסתבר שהם לא צריכים את ה-120 יום" (וכן ראו בסעיף 24 לתצהיר [redacted]).

עוד טענו ה"ה [redacted] כי מרבית השינויים שנכללו בחשבון השינויים, בגינם ניתנה הסמכתם לאיחור במסירה כאמור, היו שינויים "לחיוב יזם", קרי התחייבויות חוזיות של רום ארד, שניתנו עוד במעמד החתימה על ההסכם, ושנכללו במסגרת נספח התוספות למפרט הטכני להסכם, כ"מתנות שיווק" מטעם רום ארד לתובעים. ה"ה [redacted] טענו, כי לא היה בהטבות יזם אלו, כפי שפורטו בחשבון השינויים, כדי להצדיק האיחור האמור במסירת הדירה. בנוסף טענו ה"ה [redacted] כי חשבון השינויים היה מוכן עוד בחודש דצמבר 2013. לדבריהם, הוא לא נחתם במועד זה אך ורק בשל מחלוקת כספית בין רום ארד לבין אוריון. בנוסף נטען, כי אוריון לא ביצעה את העבודות, גם לאחר החתימה על חשבון השינויים, מאחר שרום ארד לא שילמה עבור ביצוען. גם מ טעם זה טענו ה"ה [redacted] כי לא היה מקום לאיחור במסירה כאמור.

40. אך כעולה מדבריו של [redacted] עוד במועד בו חתמו על הסיכום בדבר איחור במסירה סברו כי אין הוא מוצדק. כבר אז היו מודעים לכך שחשבון השינויים כולל הטבות יזם להן התחייבה רום ארד בהסכם, וכן שינויים שהיו ידועים עוד בחודש דצמבר 2013.

על אף זאת הסכימו ה"ה [redacted] לאיחור במסירה, וזאת במסגרת הסיכום הכולל שהושג ביום 5.8.14. אחר שה"ה [redacted] נתנו הסכמתם לאיחור במסירה, אין מקום לדיון בשאלה האם האיחור לו הסכימו היה מוצדק אם לאו.

במאמר מוסגר, ראוי להפנות לעדותו של [redacted] בחקירתו הנגדית, בגדרה אישר, כי מאז כריתת ההסכם בוצעו שינויים בתכנון הדירה, וכי תוכניות אדריכליות סופיות גובשו רק בשלהי אוגוסט, ובלשונו: "במהלך כל התקופה עד אוגוסט בוצעו לא מעט תכניות על ידי רום ארד, ואני חתמתי עליהן, התכניות כללו שינוי קירות, תכנית חשמל, תכנית מים, תכנית אבטחה, רק בסוף, עכשיו היה חלק מהזמן הייתה אותה הקפאה של פעילות, רק לקראת סוף אוגוסט יצאו התכניות האחרונות שכוללות את תכניות התאורה והנמכת הגבס. יש לי את התכניות האלה" (עמ' 118, שורות 14 – 19). עוד אישר [redacted] בחקירתו, כי למעשה הקפאת הפעילות בדירה נבעה מכך שטרם גובשו כל ההסכמות בין ה"ה [redacted] לחברה (שם, שורה 22). עדות זו מעמידה בספק את טענת ה"ה [redacted] כי לא היתה הצדקה לאיחור במסירה. כל זאת למעלה מן הצורך, בהינתן הסכמת ה"ה [redacted] לאיחור במסירה, כאמור.

41. עוד טענו ה"ה [redacted] כי הנתבעות לא ביצעו את כל העבודות בדירה והתמהמהו בהשלמתן (סעיף 25 לתצהיר [redacted]. ה"ה [redacted] הרחיבו בסיכומיהם אודות העיכובים בביצוע העבודות שנבעו, בין היתר, מהסכסוך בין רום ארד לאוריון ויציאת פועלי אוריון מהדירה קודם להשלמת העבודות בה.

בנוסף טענו, כי נוכח העיכוב בביצוע העבודות בדירה הודיע ב"כ ה"ה [redacted] עו"ד הרוש, לחברה [redacted] ההסכמה לאיחור במסירה מבוטלת (סעיף 25 לתצהיר [redacted] וכן בחקירתו, בעמ' 109, שורות 8 [redacted] לדבריהם, ניסיונה של רום ארד להסתמך על ההסכמה לאיחור במסירה עולה כדי קיום הסכם המכר ב[redacted] תום לב. ה"ה [redacted] הפנו למכתבו של עו"ד הרוש מיום 14.9.14, בטענה כי במכתב זה הודיע עו"ד הר[redacted] לאור הפרת ההסכמות מבוטלת הארכה שניתנה.

אך בניגוד לאופן הצגת הדברים על ידי [redacted] ולציטוט החלקי מהמכתב, במכתב זה לא הודיע עו"ד הרוש על ביטול הארכה, כי אם הבהיר כי ככל שלא יתקבל מענה למכתב יפנו ה"ה [redacted] לערכאות מתוך הנחה כי ה"ה [redacted] אינם מחוייבים עוד להסכמתם לאיחור במסירה, כדלקמן:

> "אבקשכם לענות לנו בכתב על הסיבה להעדר כל פעולה מצדכם בדירה נשוא ההסכם ומדוע מאז הפגישה ביום 5.8.14 בה נאמר כי הדברים יעשו במהירות האפשרית, לא נעשה דבר. במידה ולא תענו למכתבנו זה תוך 3 ימים נאלץ למצות את זכויות מרשי בערכאות המתאימות תוך שימת דגש כי בשל העדר כל פעולה דירה מטעמכם עד כה וזאת כחלוף חודש ועשרה ימים מיום המפגש האחרון, אין מרשי מחויבים לאורכה בת 120 יום אשר ניתנה לכם (האורכה הנ"ל ניתנה ע"י מרשי על סמך הצהרותיכם כי נחוצים לכם כל ה- 120 ימים אך כפי שנראה מהתנהלותכם אין לכם כל צורך בכך הימים הנ"ל דבר שרק מקומם את מרשי ועל כן אין הם מחויבים לאורכה הנ"ל על כל המשתמע)."

למעלה מן הצורך, אף לא השתכנעתי מטענת עו"ד הרוש במכתב, כי מתן הארכה היה מותנה בכל דרך, כי נסמך על הצהרות רום ארד, וכי ניתן היה לבטלה באופן חד צדדי אך ורק בשל התרשמות ה"ה [redacted] מקצב עבודה בלתי מספק. זאת בפרט מאחר ש"ה [redacted] לא ביטלו את מכלול ההסכמות שהושגו ביום 5.8.14. אין

לקבל הטענה כי באופן סלקטיבי, בשל התרשמות בדבר עיכוב בביצוע העבודות, יכולים לסגת בהם ה"ה [redacted] מחלקים מהסיכום, מבלי לוותר על חלקיו האחרים של הסיכום.

מעבר לכך, לא הוצג ביסוס ראייתי מספק לעיכוב בביצוע העבודות שהיה בו כדי להצדיק את ביטול ההסכמה לאיחור במסירה. זאת בפרט מאחר שאין חולק כי על אף הסכסוך בין רום ארד לאוריון בוצעו עבודות בדירה בידי קבלני משנה אחרים.

מסקנה זו מתחייבת מאחר שבפועל נחתם פרוטוקול מסירה עוד ביום 20.11.14, במסגרת לוחות הזמנים שהוסכמו על ידי הצדדים, וכי במועד זה נותרה השלמת עבודות קלות בלבד בדירה – כל זאת כפי שארחיב להלן.

פרוטוקול המסירה מיום 20.11.14

42. לטענת ה"ה [redacted] הם נכנסו לדירה רק באמצע חודש אוגוסט 2015. ברם אין חולק, כי כבר ביום 20.11.14 חתם [redacted] על פרוטוקול מסירה, במסגרתו אישר [redacted] כי קיבל את הדירה (להלן: "פרוטוקול [redacted] החתימה על פרוטוקול המסירה נעשתה, אם כן, במסגרת לוחות הזמנים, לאחר שה"ה [redacted] לאיחור במסירה, כמפורט לעיל.

ה"ה [redacted] לא הכחישו את חתימתו של [redacted] ע"ג פרוטוקול המסירה. עם זאת, לטענתם, מדובר [redacted] מסירה פיקטיבי, שנועד לקידום עבודות הסבת המחסן, וכי בפועל הדירה לא היתה מוכנה ל [redacted] הותקנו בה כלים סניטאריים, וכן לא הושלמו הריצוף ועבודות החשמל.

[redacted] טען בתצהירו, כי במועד החתימה על פרוטוקול המסירה, כלל לא נכנסו ה"ה [redacted] לדירה, משום שהיה ידוע לכל, כדבריו, כי באותו השלב הדירה לא היתה ראויה למגורים. הוא העיד, כי נכון לחתימת פרוטוקול המסירה היו עדיין לאנשי רום ארד מפתחות לדירה, והם נכנסו ויצאו ממנה ללא צורך בתיאום עם ה"ה [redacted] וכן טען, כי בשלב זה לא ניתן היה לנהוג בדירה מנהג בעלים, וכי אף רום ארד וקבלן המשנה המשיכו להתנהל "כתמול שלשום", כאילו לא נמסרה הדירה (סעיפים 31, 36 לתצהיר [redacted]. אך לא התרשמתי מהיות פרוטוקול המסירה פיקטיבי כנטען.

אין חולק, כי [redacted] חתם מרצונו על פרוטוקול המסירה, במסגרתו אישר כי הדירה התקבלה ביום 20.11.14. החתימה על פרוטוקול המסירה לא נכפתה על [redacted] ההיפך הוא הנכון. כפי שניתן להתרשם מתמלילי השיחה אליהם הפנו ה"ה [redacted] אשר אודותיהם ארחיב להלן, החתימה על פרוטוקול המסירה נועדה לייצר מצג לרשויות בדבר מסירת הדירה, על מנת להחיש את תחילת ביצוע עבודות הסבת המחסן – ללא היתר. עבודות הסבת המחסן ללא היתר כאמור היו עבודות שה"ה [redacted] ביקשו לבצע, כך שבעניין החתימה על פרוטוקול המסירה – אין להי"ה [redacted] להלין אלא על עצמם.

43. לתצהירו של [redacted] צורפו שורה של תמלילי שיחות, שהוקלטו על ידי [redacted] המתעדים את הרקע לחתימה על פרוטוקול המסירה. מכולם עולה, כי החתימה על פרוטוקול המסירה נועדה לצרכי הצגה לרשויות ועל מנת לאפשר תחילת עבודות הסבת המחסן ללא היתר.

כך, בתמליל שיחה שהתקיימה בין [redacted] לבין [redacted] [redacted] ביום 6.11.14, ביקש [redacted] מ[redacted] לערוך פרוטוקול מסירה, ללא קשר למצבה של הדירה, כדלקמן (עמ' 2 לתמליל, שורות 25 – 27):

"זה לא מעניין באיזה מצב היא, תעשה פרוטוקול מסירה סתם, שיהיה לי פרוטוקול מסירה עם התאריך של היום וחתימה, תרשום מצידי שהדירה לא במצב זה, תרשום מה שאתה רוצה, אבל אני רוצה ..."

בהמשך, הבהיר [redacted] כי לשם ביצוע עבודות הסבת המחסן, נדרש כי קודם לכן תבוצע מסירה פורמאלית של הדירה, כדלקמן (עמ' 3, שורות 5 – 6):

" ... אמרתי לך שיש לי בעיה לעשות עבודות בדירה, במחסן, אתה חייב לקבל את הדירה הפורמאלית שיהיה לי טופס שמסרתי אותה."

בשל כך, ביטא [redacted] את הסכמתו לחתימה על פרוטוקול המסירה, אף כי הבהיר כי מדובר באישור פורמאלי בלבד לצרכי יצירת מצג לרשויות כי הדירה נמסרה, כדלקמן (עמ' 4, שורות 22 – 25):

" ... עכשיו אני סיכמנו שאני אלך לקראתכם בחלק הפורמאלי מול הרשויות אם אתה צריך להראות אישור שקיבלתי את הדירה מבחינתי זה בסדר הנה קח את האישור, אבל זה לא מסירה אמיתית זה לא מסירה של בית"

[redacted] אף התחייב להסדרת יתרת התשלום עבור הדירה בתוך חודש (עמ' 5, שורה 5).

מתמליל שיחה זה עולה, אם כן, כי [redacted] הסכים לחתום על פרוטוקול המסירה, לצרכי קידום עבודות הסבת המחסן. עוד עולה, כי [redacted] היה ער לעובדה כי אין המדובר במסירה מלאכותית, כי אם במסירה כנגד הסדרת מלוא התשלום עבור הדירה – אותה התחייב לבצע.

44. בתמליל שיחה במעמד מספר דוברים, בהם [redacted] [redacted] [redacted] ועו"ד [redacted] מיום 10.11.14, הבהיר [redacted] כי פרוטוקול המסירה נחוץ כ"תעודת ביטוח", לכך שה"ה [redacted] לוקחים על עצמם את הסבת הדירה. הוא ציין, כי עותק פרוטוקול המסירה יושם בכספת, וכי עותק ממנו לא יועבר לה"ה [redacted] כדלקמן (עמ' 1, שורות 23 – 28):

" ... אני מבקש כזה דבר ... תוך יום יומיים לא יותר שבו תעשו מסירה, אתה יכול לרשום במסירה מה שאתה רוצה זה לא ילך אליך, אין לך עותק, אתה לק מקבל עותקים, אתה חותם על נייר שקיבלת את הדירה, ובא אלי לכספת, ... לקחת טופס, לא חוקיות בתוך הדירה, אני רוצה שיהיה לי תעודת ביטוח שאתה תדאג על דעת עצמך בפרויקטים שלך, והנה מסרתי לך את הדירה, הרי פשוט על השולחן."

בשלב מסוים אישר עו"ד [redacted] בשיחה, כי העבודות בדירה טרם הסתיימו, ואף הציע כי ערבויות חוק המכר שקיבלו ה"ה [redacted] יוחזקו בנאמנות אצל ב"כ ה"ה [redacted] עד לגמר העבודות בדירה, כדלקמן (עמ' 2, שורות 15 – 16):

" ... אתה רוצה שאני יחזיק (כך במקור) את הערבויות ביחד עם העורך דין שלך? עד שהדירה תיגמר ..."

בהמשך, הציע אחד הדוברים (זהותו לא ברורה) כי ייקבע מועד לסיום העבודות, וכי רק לאחר השלמת העבודות תימסרנה הערבויות, כדלקמן (עמ' 3, שורות 8 – 9):

" ... קובעים לו"ז לסיום העבודות נגיד קובעים יום 20 יום, מה שקבעתם מסיימים את העבודות ואז ... את הערבויות ... "

משיחה זו משתמע, כי אכן [redacted] ועו"ד [redacted] הכירו בכך שהלכה למעשה מתבצעת מסירה של הדירה קודם להשלמת העבודות, אף כי נדרשו 20 ימי עבודה לסיום העבודות ולהשבת הערבויות לאחר מכן.

45. בתמליל שיחה בין [redacted] עו"ד [redacted] [redacted] מיום 17.11.14, פירט ע ו"ד [redacted] את הסיכום בין הצדדים, כדלקמן (עמ' 2, שורות 11 – 13):

"[redacted] סגרנו? גמר חשבון הוא עושה עד יום חמישי הוא מוסר את הערבויות פרוטוקול מסירה ואתם עובדים על האמבטיה, הקבלן מתחייב כרגע שיש פרוטוקול מסירה עד יום חמישי עובדים על האמבטיה."

מדברים אלה ניתן להבין, כי סוכם על חתימה על פרוטוקול המסירה, וכי ערבויות חוק המכר שקיבל [redacted] יוחזרו לאחר גמר חשבון (במאמר מוסגר, רום ארד לא הכחישה, כי ערבויות חוק המכר לא נדרשו מה"ה [redacted] עד היום).

46. מתמלילי השיחות שצורפו ניתן ללמוד, כי החתימה על פרוטוקול המסירה נועדה לייצר מצג לרשויות בדבר מסירת הדירה, על מנת להחיש את תחילת ביצוע עבודות הסבת המחסן – ללא היתר, אף כי עדיין נותרו עבודות מסויימות בהיקף מצומצם של מספר ימי עבודה בדירה (ראו גם להלן).

[redacted] אמנם העיד, כי הסכים להצעת רום ארד לחתום על פרוטוקול המסירה מאחר שהרגיש שהוא בין "הפטיש לסדן", ועל מנת לצמצם את נזקיו ולקדם את השלמת העבודות בדירה (סעיף 34 לתצהיר [redacted]). אך למעשה החתימה על פרוטוקול המסירה לא נועדה להבטיח את השלמת העבודות בדירה, חרף טענתו של [redacted] כי אם לאפשר את הסבת המחסן ללא היתר, על פי דרישתם של ה"ה [redacted] על כן אין לראות בחתימה על פרוטוקול המסירה ככזו שנכפתה על ה"ה [redacted] בלית ברירה.

על רקע האמור, תביעתם של ה"ה [redacted] לפיצוי בגין איחור במסירה, מקום בו חתם [redacted] ביודעין על [redacted] פרוטוקול מסירה על מנת להכשיר עבודות להסבת המחסן ללא היתר, מעוררת תהיות. אין ליתן לסיכום מפוקפק לפיו פרוטוקול המסירה תקף לצרכי מצג לרשויות ולשם זירוז עבודות הסבת המחס היתר, אך אינו מחייב במישור היחסים שבין ה"ה [redacted] לחברה.

47. בחקירתו הנגדית טען [redacted] לראשונה, כי הסכים לחתום ע"ג פרוטוקול המסירה על מנת לעשות פ ומתוך הבנה כי יקבל פיצוי בסך של 16,000 ₪ בגין כך, כדלקמן (עמ' 110, שורות 15 – 18): "בגדול שטות שלקחתי, אבל לקחתי את זה לעשות את הפרגולה שהייתם אמורים לעשות ולא עשיתם, והגעתי להבנה עם [redacted] שמפצים אותי ב-16 אלף שקל ואני עושה את זה וזאת הסיבה שלקחתי את המפתח".

גרסה זו לא הועלתה עד לשלב החקירה הנגדית, וככזו היא מוטלת בספק. אך מכל מקום, אף בגרסה זו יש משום אישוש למסקנה כי החתימה על פרוטוקול המסירה נעשתה באופן מודע ומוסכם, כנגד קבלת פיצוי, גם אם עוד קודם להשלמת העבודות בדירה. מעבר לכך, יש בדבריו אלה של [redacted] משום אישור לכך שבוצעה במעמד זה מסירה בפועל של הדירה, על מנת לאפשר לה"ה [redacted] לבצע בה עבודות פרטיות. על כן גם לפי גרסה זו, אין מקום ליתן להה"ר [redacted] סעד בגין העיכוב במסירת הדירה.

48. עולה, אם כן, כי ה"ה [redacted] הסכימו לארכה בת 120 ימי עבודה למסירת הדירה ביום 14.8.14, וכי [redacted] חתם על פרוטוקול מסירה ביום 20.11.14, עוד קודם לחלוף תקופת הארכה לה הסכימו ה"ה [redacted] די באמור כדי לשמוט הקרקע תחת טענותיהם של ה"ה [redacted] לפיצוי בגין איחוד במסירה.

למעלה מן הצורך, לא השתכנעתי כי היקף העבודות שלא הושלמו בדירה היה משמעותי, וכי ה"ה [redacted] נכנסו לדירה בפועל רק באמצע חודש אוגוסט 2015, כפי שאבאר להלן.

לא הוכח כי ה"ה [redacted] נכנסו לדירה רק באמצע חודש אוגוסט 2015

49. ל טענת ה"ה [redacted] בפועל הם נכנסו לדירה רק באמצע חודש אוגוסט 2015. לא השתכנעתי מטענה זו.

ה"ה [redacted] לא הציגו כל ביסוס ראייתי לטענה בדבר מועד מסירת הדירה בפועל. מהראיות שהוצגו על ידי ה"ה [redacted] אף ניתן ללמוד, כי בניגוד לנטען, הלכה למעשה נכנסו ה"ה [redacted] לדירה כבר ביום 20.11.14.

בחקירתו הנגדית אישר [redacted] כי במעמד החתימה על פרוטוקול המסירה קיבל לידיו מפתח לדירה (עמ' 110, שורה 9, עמ' 121, שורה 4). מעבר לכך, וכפי שהרחבתי לעיל, [redacted] אישר בחקירתו, כי הסכים לקבל את הדירה עוד קודם להשלמת העבודות בה, לשם ביצוע עבודות פרטיות אותן ביקשו ה"ה [redacted] לבצע בדירה. משמע שמסירת הדירה אכן בוצעה בחודש נובמבר 2014, ולא כפי שביקשו ה"ה [redacted] לטעון.

50. ה"ה [redacted] הפנו לשורה של הודעות דוא"ל ששלח [redacted] לנציגי רום ארד, לאחר החתימה ע[redacted] המסירה (בתאריכים 12.1.15, 11.4.15), וכן למכתבי ב"כ [redacted] (מכתב עו"ד הרוש מיום 15.[redacted] עו"ד בן אריה מיום 26.5.15), בהם מלינים [redacted] ובא כוחו על כך שהדירה טרם נמסרה. ברם ארד דחתה בזמן אמת את הטענות לאי המסירה, ואפנה, לשם התרשמות, להודעת דוא"ל מטע[redacted] מיום 12.5.15 , בה הוא דוחה הטענה לאי מסירה וטוען כי הדירה נמסרה לה"ה [redacted] לשם עבו[redacted]

מעבר לכך, במכתב ב"כ ה"ה [redacted] עו"ד דב דוניץ, מיום 17.11.15 כתב עו"ד דוניץ באופן מפורש כי מסירת הדירה התבצעה כבר ביום 20.11.14, וכי ה"ה [redacted] התגוררו בפועל ממועד זה בדירה (כך שנכון למועד משלוח המכתב התגוררו ה"ה [redacted] בדירה מזה 13 חודשים), כדלקמן (סעיפים 2 – 5 למכתב):

> "מרשינו רכשו מכם את דירתם ... ביום 17.11.2013. את מפתח הדירה קיבלו לידיהם ביום 20.11.2014 ... אין הדעת סובלת מצב עניינים בו מתגוררים מרשינו בדירה זה 13 חודשים ארוכים כאשר דוד השמש שבדירה אינו מחובר לרשת החשמל ומערכת האינטרקום של הבניין אינה פועלת (לפחות בדירה). למותר לציין שמדובר בעבודות אותן היה עליכם להשלים טרם מסירת הדירה לידי מרשינו."

משמע שה"ה [redacted] אכן קיבלו את המפתח לדירה, ואף התגוררו בדירה, הלכה למעשה, ממועד חתימת פרוטוקול המסירה.

בסיכומיהם, טענו ה"ה [redacted] כי מכתב זה נשלח בטעות, וכי נשלח מכתב מתקן תחתיו. אך אותו מכתב מתקן לא צורף, ובהיעדר הסבר כלשהו למקורה של הטעות הנטענת, אין בעצם העלאת הטענה בעניין די. זאת בפרט מאחר שלא התרשמתי מקיומה של מניעה מעשית מלגור בדירה, ובהיעדר תיעוד כלשהו למועד בו נכנסו ה"ה [redacted] בפועל לדירה, כפי שאבאר להלן.

51. ה"ה [redacted] לא הוכיחו כי היתה מניעה מעשית להתגורר בדירה במהלך כל התקופה בה טענו כי הדירה לא היתה ראויה למגורים.

[redacted] טען בתצהירו כי היה "ידוע לכל", כי הדירה אינה ראויה למגורים במועד החתימה על פרוטוקול המסירה. אך דווקא מעדותו של [redacted] בתצהיר על העבודות שהיו טעונות השלמה בדירה במועד החתימה על פרוטוקול המסירה ניתן להתרשם, כי נותרו עבודות ממוקדות וקלות, שלכל היותר נדרשו ימים בודדים לשם השלמתן, כדלקמן (סעיף 36 לתצהיר [redacted]): " ... לשם ההמחשה, ובין השאר, החשמל בדירה טרם נבדק ועדיין היו בדירה שקעים פתוחים ללא כיסוי בקליט, ריצוף חסר והכלים הסניטריים (אסלות כיורים וכו') לא הותקנו ולפיכך לא ניתן היה, ואף מסוכן היה, לעשות בדירה שימוש ליעודה."

לבטח שאין בבדיקת חשמל, כיסוי שקעים פתוחים, התקנת כלים סניטריים והשלמת ריצוף חסר (בהיקף שלא פורט) כדי להצדיק עיכוב של כתשעה חודשים בכניסה לדירה, כפי טענת ה"ה [redacted]

ה"ה [redacted] לא סיפקו כל הסבר לפשר השיהוי בכניסה לדירה, זולת הטענה הסתמית כי העבודות בה טרם הושלמו. הם אף לא הציגו כל ביסוס ראייתי לעיתוי בו נמסרה להם הדירה בפועל, וכן נמנעו מלנקוב בתאריך ספציפי בו נמסרה הדירה. תחת זאת, הסתפקו בטענה הכללית כי כניסתם לדירה התרחשה "באמצע" חודש אוגוסט.

52. מעבר לכך, ה"ה [redacted] נמנעו מלפרט ברחל בתך הקטנה אלו עבודות עיכבו את הכניסה לדירה עד לחודש אוגוסט 2015. הם הפנו בסיכומיהם לעדותו של [redacted], שלא הכחיש בחקירתו הנגדית כי בחודש מאי 2015 עדיין נותרו עבודות בהיקף לא מבוטל בדירה (עמ' 201, שורה 24). עוד הפנו ה"ה [redacted] למסמכי העירייה לבקשת רום ארד לקבלת פטור מתשלום ארנונה עבור הדירה בגין "נכס לא ראוי למגורים". הם טענו כי העירייה הכירה בכך שה"ה [redacted] נכנסו לדירה באוגוסט 2015, וכי הדחיות בחיוב בארנונה, באו עקב בקשות רום ארד, בעוד ה"ה [redacted] בעצמם מעולם לא ביקשו פטור מארנונה על הדירה.

אך לכל היותר יש בראיות אלה כדי ללמד, כי אכן הדירה נמסרה קודם להשלמת העבודות הפרטיות בה, כמוסכם, וכי ה"ה [redacted] ורום ארד לא שילמו ארנונה בגינה עד לחודש אוגוסט 2015 כאמור. אין בהן כדי ללמד, כי הדירה לא נמסרה, הלכה למעשה, עוד קודם לכן, או בדבר היקף העבודות שנותרו להשלמה ומשך הזמן שנדרש לשם השלמתן.

53. אזכיר, כי מתמלילי השיחות והתכתובות שצורפו לתצהירו של [redacted] כפי שנסקרו לעיל, כמו גם מהעדות שמסר [redacted] עצמו בחקירתו, עולה הרושם כי העבודות ש[redacted] טען כי יש להשלימן בדירה לאחר החתימה על פרוטוקול המסירה – אינן העבודות אודותיהן העיד [redacted] כעבודות שהיו טעונות השלמה בעת החתימה

על פרוטוקול המסירה. מדובר בעבודות נוספות, פרטיות, אותן ביקשו ה"ה [redacted] לבצע בדירה לאחר מסירת החזקה, ובכללן הסבת המחסן.

אף לא השתכנעתי כי הלכה למעשה העבודות שהיו טעונות השלמה בחודש מאי 2015 היו כאלה שהיה בהן כדי לעכב מסירת הדירה ומגורים בדירה בפועל. לשם התרשמות אפנה לפרוטוקול העבודות בדירה מיום 27.5.15, שנכתב בכתב יד, הכולל עבודות קלות להסדרת ליקויים, שככלל אין בהן כדי לעכב מסירה – ושלבטח אין בהן כדי להצדיק חודשים של מגורים מחוץ לדירה, כדוגמת החלפת מנעול בחדר שינה, החלפת גלגלים לויטרינות (מאחר שהם "זזים קשה"), שלבי תריס פגומים, עבודות צבע ממוקדות (במקום בו היתה רטיבות), תיקון עבודת צבע סביב קופסאות חשמל, ניקוי דלת ממ"ד ועוד.

54. סיכומם של דברים, אין מקום לפיצוי בגין איחור במסירה. ה"ה [redacted] אישרו איחור במסירה של 120 ימי עבודה, ומסירת הדירה בוצעה קודם לחלוף תקופת ההארכה. [redacted] חתם על פרוטוקול מסירה המתעד את עיתוי מסירת הדירה, וזאת מרצונו, ולשם קידום ענייני הסבת המחסן. על כן אין להה"ה [redacted] להלין כי מדובר בפרוטוקול מסירה פיקטיבי. אף לא הוכח כי הדירה נמסרה בפועל רק תשעה חודשים לאחר החתימה על פרוטוקול המסירה. זאת גם אם במועד זה נותרו עדיין עבודות קלות להשלמה בדירה.

<u>פיצוי בגין ליקויי בניה ותוספות</u>

55. בחוות דעתו, נדרש המהנדס [redacted] לשורת ליקויי בניה, וכן לאי התאמות ולתוספות הנדרשות בדירה. המהנדס [redacted] קבע, כי לא התגלה ליקוי יסודי כלשהו, וכי כל הליקויים ניתנים לתיקון באופן סביר. הוא העריך את פרק הזמן לשם תיקונם בכ- 21 ימי עבודה, וקבע, כי אין מניעה להמשיך ולהתגורר בדירה בזמן ביצוע התיקונים. המהנדס [redacted] אמד את עלות תיקון הליקויים בדירה בסך של 73,489 ₪ (כולל מע"מ) ואת עלות הסדרת התוספות בסך של 48,145 ₪ (כולל מע"מ), ובסך כולל של 121,634 ₪ (סעיפים י"א (1 – 2) לחוות דעת [redacted] . ה"ה [redacted] לא השיגו על קביעותיו של המהנדס [redacted] בעניין ליקויי בניה ותוספות בסיכומיהם.

לטענת רום ארד, נוכח העבודות הפרטיות הנרחבות שביצעו ה"ה [redacted] בדירה "נותק הקשר הסיבתי בין העבודות שבוצעו בדירה בידי אוריון לבין הליקויים הקיימים בה היום" (סעיף 36 לסיכומי רום ארד). לא מצאתי בטענה זו ממש. המהנדס [redacted] קבע כי יש מקום לפצות ה"ה [redacted] בגין הליקויים שנמצאו בדירה בהיקף שפורט לעיל. קביעתו זו ניתנה על אף שטענתה זו של רום ארד, כי אינה אחראית לליקויים, עמדה לנגד עיניו (סעיף ט(2) לחוות דעת המהנדס [redacted] . קביעותיו אלה של המהנדס [redacted] לא נסתרו. טענת רום ארד כי מקור הליקויים בעבודות פרטיות שביצעו ה"ה [redacted] נטענה כלאחר יד, ללא ביסוס וללא תימוכין, ומבלי שרום ארד תפנה אף לקביעות המומחה מטעמה בעניין. על כן דין טענה זו להידחות.

עוד טענה רום ארד, כי יש להשית את עלות התיקונים על אוריון. איני מקבלת טענה זו. רום ארד היא שהתקשרה בהסכם המכר עם התובעים, והיא הנושאת באחריות להסדרת הליקויים מול התובעים. גם אם בפועל הגורם שביצע באופן רשלני את העבודות הוא קבלן משנה, שאינו רום ארד, אין בכך כדי להשיל מעל רום ארד את אחריותה לאיכות הדירה שסופקה. אפנה בהקשר זה להוראותיו המפורשות של סעיף 3.3 סיפא להסכם המכר, אודותיו ארחיב להלן, לפיהן אין בטענות כלפי עבודת קבלן עבודת המשנה כדי לגרוע מאחריות רום ארד. למעלה מן הצורך, אף לא הוצג ביסוס ראייתי לכך שהליקויים שאותרו בדירה נבעו מכשלים בעבודת אוריון, כפי שאבאר להלן.

56. רום ארד העלתה שורה של השגות על חוות דעת המהנדס [redacted] להן אדרש כדלקמן:

רטיבות מתחת לשכבת האיטום במרפסת

57. בחוות דעתו מצא המהנדס [redacted] כי קיימת חדירת רטיבות מתחת לשכבת האיטום באגף הדרו המרפסת הדרומית. הוא הביא מדברי הדייר בדירה הממוקמת מתחת לדירת ה"ה [redacted] שציין כי ר זו חודרת אל תקרת חדר ההורים בדירתו. המהנדס [redacted] קבע, כי מקור הרטיבות בפתחים שפתחו ה"ה [redacted] במרפסת לאחר קבלת הדירה לצורך העברת צנרת מים לג'קוזי ולפינת מנגל אותם התקינו. לדבריו, קיים סיכוי גבוה כי האיטום נפגע בשל עצם הרמת האריחים ופירוקם. לצד זאת, ציין המהנדס [redacted] כי רום ארד לא עמדה בנטל ההוכחה כי ביצעה איטום כנדרש, ולא המציאה לו לבקשתו תשריט חתך טיפוסי של קיר המרפסת. מטעם זה קבע, כי באחריותה של רום ארד לבצע את התיקון. את עלות התיקון אמד המהנדס [redacted] בסך של 5,000 ₪ (סעיף 1.6.2 לטבלה נספח א' לחוות דעת המהנדס [redacted].

רום ארד הפנתה לעדותו של המהנדס [redacted] בחקירתו, בה אישר, כי אין המדובר בליקוי המצוי בדירת ה"ה [redacted] כי אם בליקוי בדירה שמתחת לדירת ה"ה [redacted] (עמ' 58, שורה 17). מאחר שכך, אין מקום לפיצוי ה"ה [redacted] בגין ליקוי זה, ודין טענות רום ארד בעניין להתקבל.

58. עוד מצא המהנדס [redacted] בחוות דעתו, כי קיימת רטיבות רבה המתפשטת ברצפת המילוי שמתחת לריצוף בשטח המרפסת עקב איטומי רובה חסרים ומתפוררים במספר מקומות בתפזורת. המהנדס [redacted] קבע כי נדרש לפתוח את הריצוף ולבצע איטום של המרפסת, לרבות רובה, כמקובל. המהנדס [redacted] אמד את עלות התיקון בסך של 2,000 ₪ (סעיף 1.6.3 לטבלה נספח א' לחוות דעת [redacted]. בנוסף, מצא המהנדס [redacted] כי שיפועי הריצוף במרפסת, הן באגף המערבי והן בסמוך למסילת הויטרינה, אינם עומדים בתקינה הישראלית הדרושה. המהנדס [redacted] קבע, כי אחוז השיפוע הקיים תקין, למעט שטח של 3 מ"ר בו נדרש לערוך תיקון בשיפועי הריצוף. המהנדס [redacted] אמד את עלות התיקון בסך של 2,400 ₪ (סעיף 1.6.4 לטבלה נספח א' לחוות דעת [redacted].

רום ארד הפנתה לעדותו של המהנדס [redacted] בחקירתו, בה אישר, כי קיימת חפיפה בין פעולות התיקון לפי סעיף 1.6.3 לטבלה שבנספח א' לחוות דעתו לצרכי הסדרת הרטיבות לבין פעולות התיקון לבין פעולות התיקון לפי סעיף 1.6.4 לטבלה שבנספח א' לחוות דעתו לצרכי הסדרת שיפועי הריצוף במרפסת (עמ' 61, שורה 7). מאחר שכך, די בפיצוי בסך של 2,400 ₪ לשם הסדרת הליקויים, ואין מקום לפיצוי נוסף בסך של 2,000 ₪ בגין כך.

חיסום לוחות הזכוכית בהיקף המעקות

59. המהנדס [redacted] מצא, כי בלוחות הזכוכית בהיקף המעקות לא קיימת הטבעה המעידה על חיסו [redacted] כי יש מקום לדרוש מהיצרן אישור על תקינות הזכוכית, כן כי רום ארד לא עמדה בנטל ההוכח המהנדס [redacted] אמד את עלות הסדרת העניין בסך של 2,000 ₪ (סעיף 4.2 לטבלה נספח א' לחוות [redacted]

בחקירתו הנגדית נשאל המהנדס [redacted] על ידי ב"כ ה"ה [redacted] על עלות החלפת מעקה הזכו [redacted] תקני. במענה לכך הבהיר המהנדס [redacted] כי בחוות דעתו יצא מנקודת הנחה כי המעקה עומד ב נפקד האישור על עמידתו בתקן, ולכן לא אמד את עלות החלפת המעקה (עמ' 30, שורה 24, עמ' 31, שורה 1). ב"כ ה"ה [redacted] שב ושאל את המהנדס [redacted] מה עלות החלפת המעקה במקרה בו יוכיחו ה"ה [redacted] כי המעקה אכן אינו עומד בתקן. במענה לכך, וכן לשאלת בית המשפט בעניין, התחייב המהנדס [redacted] להמציא אומדן של עלות החלפת המעקה (עמ' 31, שורה 16). בהודעת דוא"ל ששלח המהנדס [redacted] לב"כ התובעים ביום 26.8.21 הבהיר המהנדס [redacted] כי במידה שיוכח כי המעקה הנוכחי אינו תקני, הרי שעלות התקנה של מעקה מסוג זה היא כ- 55,000 ₪ בצירוף מע"מ, וכן כי עלות פירוק וסילוק המעקה הקיים היא כ- 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.

לטענת רום ארד, התובעים כלל לא תבעו פיצוי בגין ליקוי זה. רום ארד הפנתה בעניין זה לעדות שמסר המהנדס [redacted] בחקירתו, בה אישר הדבר (עמ' 64, שורה 20, עמ' 65 ,שורה 4). התובעים אף לא תיקנו את כתב תביעתם לאחר קבלת חוות דעת המהנדס [redacted] בעניין. למעלה מכך, התובעים לא הוכיחו כי אכן המעקה אינו תקני, ומאז קבלת הבהרתו של המהנדס [redacted] בעניין עלות החלפת המעקה כאמור לא הוצגו עוד ראיות מטעם התובעים בעניין.

אכן ה"ה [redacted] לא תבעו פיצוי בגין המעקה, ואף לא הוכיחו כי אינו תקני. בסיכומיהם תירצו ה"ה [redacted] הדבר בכך שסברו, כמהנדס [redacted] כי רום ארד תמציא אישור התקן, אך טענו, כי אחר שהאישור לא הומצא, ומאחר שהסכום שנתבע בגין ליקויי בניה ואי התאמות גבוה מהסכום שנקבע על ידי המהנדס [redacted] לצורך החלפת המעקה, הרי שיש לקבל את חוות דעתו של המהנדס [redacted] ולאשר התוספת של 65,000 ₪ שנתבעה. איני מקבלת את טענתם.

סוגיית החלפת המעקה לא היוותה חזית מחלוקת בין הצדדים, לא נתבע פיצוי בגין החלפת המעקה, והדבר לא נכלל אף בחוות הדעת מטעם התובעים. בנסיבות אלה, ובפרט בהיעדר ביסוס ראייתי לכך שהמעקה אינו תקני, אין מקום להורות על פיצוי כלשהו בגין המעקה. בנסיבות אלה, אין בעובדה כי ה"ה [redacted] העמידו את תביעתם על סכום הגבוה מהסכום אותו קבע המהנדס [redacted] כשלעצמה כדי להצדיק מתן פיצוי כאמור.

עלויות בלתי צפויות מראש והפחתת שיעור של 20% בגין ביצוע ע"י קבלן מנוסה

60. באומדן עלויות תיקוני הליקויים כלל המהנדס [redacted] עלויות בלתי צפויות מראש (בצ"מ) בשיעור של 10% (סעיף י"א(1) לחוות דעת [redacted] . לטענת רום ארד , ה"ה [redacted] עצמם לא טענו כי יש צורך בבצ"מ, לא תבעו תוספת זו ולא תיקנו את כתב התביעה ביחס לרכיב זה. איני מקבלת את טענת רום ארד. עלויות בלתי צפויות מראש הן חלק מהאומדן הכולל של עלויות הסדרת הליקויים בחוות דעת [redacted] הכללת בצ"מ באומדן עלויות התיקונים מקובלת ונפוצה. ראוי להפנות להבהרותיו של המהנדס [redacted] לעניין השיקולים להכללת בצ"מ באומדן העלויות (עמ' 38, שורות 21 – 24, עמ' 39, שורה 1). הבהרות אלה לא הופרכו, ולא הוצגה הצדקה ענייינית מדוע לא ייכלל בצ"מ באומדן העלויות כאמור.

אף לא התרשמתי מהטענה כי לא נכלל בצ"מ באומדן עלויות הסדרת התיקונים שבחוות דעת האדריכל [redacted] מטעם התובעים. אמנם נפקדה התייחסות מפורשת לבצ"מ בחוות הדעת. אך האדריכל [redacted] לא נחקר על חוות דעתו, ועל אופן אומדן העלויות שבה, כך שלא ניתן לשלול באופן מפורש התחשבות בבצ"מ באומדן כאמור.

61. עוד טענה רום ארד, כי יש להפחית מעלות התיקונים שיעור של 20% בגין ביצוע ע"י קבלן מנוסה. גם טענתה זו של רום ארד נטענה כלאחר יד, ללא ביסוס וללא הפנייה לכל קביעה שבמומחיות בעניין, שיש בה כדי להפריך את אומדן עלויות שבחוות דעת [redacted] על כן דינה להידחות.

תוספות ומחויבות כלפי ה"ה [redacted]

62. כאמור, המהנדס [redacted] אמד את היקף התוספות הנדרשות בדירה, להן התחייבה רום ארד, בסך של 48,145 ₪ (כולל מע"מ) (סעיף י"א (2) לחוות דעת [redacted] . בכלל זה קבע המהנדס [redacted] כי יש מקום לזיכוי ה"ה [redacted] בסך של 7,500 ₪ בגין ארון מטבח, וזאת בשל הנחתו כי ה"ה [redacted] קיבלו זיכוי חלקי בלבד, בסך של 22,500 ₪, ובלשונו (סעיף 3 לטבלה נספח ב לחוות דעת [redacted] : "ארון מטבח : זוכה 22,500 ₪ במקום 30,000 ₪ כמצוין בהסכם התוספות כולל מע"מ".

לטענת רום ארד, הזיכוי החלקי שקיבלו ה"ה [redacted] בגין ארון המטבח הוא בהתאם להסכמות הצדדים, כפי שתועדו בפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 שצורף לראיות ה"ה [redacted] אודותיו הרחבתי לעיל. בסעיף 10

לפרוטוקול זה תועדה הסכמה לכך שה"ה [redacted] יזוכו "בעלות של 22,500 ₪ בעבור המטבח ע"פ סעיף 10 בהסכם". נוכח תוקפן המחייב של ההסכמות שבפרוטוקול הפגישה, כמבואר לעיל, אין הצדקה לחיובה של רום ארד בפיצוי נוסף בגין ארון המטבח. על כן דין טענותיה של רום ארד בעניין זה להתקבל.

63. עוד קבע המהנדס [redacted] בחוות דעתו, כי לא התקבל זיכוי מרום ארד בגין אי ביצוע שתי פרגולות מקורות בטון 60*20 ס"מ, בעלות כוללת של 16,000 ₪. המהנדס [redacted] נסמך בקביעתו על הודעת דוא"ל מ[redacted] מיום 19.10.14, לפיה זכאים ה"ה [redacted] לתשלום פיצוי מרום ארד בגין אי הקמת פרגולה, בסך של 14,000 ₪, וכן על נוסח הסכם מיום 11.11.15, לו הוסף סעיף המציין כי ככל שרום ארד לא תעמיד להה"ה [redacted] אמצעי להקמת קורות עץ לבניית פרגולה, היא תשלם סכום נוסף בסך של 2,000 ₪ (סעיף 5 לטבלה נספח ב לחוות דעת[redacted] .

רום ארד לא הכחישה את התחייבותה החוזית כלפי ה"ה [redacted] כמפורט בחוות דעת [redacted] עם זאת, טענה רום ארד, כי הוצג [redacted] בחקירתו הנגדית גמר חשבון, ממנו עולה, כי ה"ה [redacted] קיבלו זיכוי בגין הפרגולה. לחילופין, טענה רום ארד, כי אוריון היא שהתחייבה לבצע את השינויים וההתחשבנות בינה לבין רום ארד אינה קשורה להה"ה [redacted] כך שככל שאוריון סברה כי היה על רום ארד לשאת בעלות חלק מהשינויים, הדבר אינו מסיר ממנה את החובה לבצעם בהתאם לחשבון השינויים שנחתם בינה לבין ה"ה [redacted] לא השתכנעתי מטענותיה אלה של רום ארד. רום ארד לא הציגה כל ראיה לכך שניתן להה"ה [redacted] זיכוי בפועל בגין הפרגולות. האסמכתא היחידה לה הפנתה רום ארד בעניין זה היתה פרוטוקול חקירתו הנגדית של [redacted] במהלכה טענה ב"כ רום ארד כלפי [redacted] כי בחשבון הסופי ניתן לראות זיכוי בגין הפרגולות (עמ' 111, שורה 1). אך רום ארד נמנעה מלהפנות לחשבון הסופי ולזיכוי הנטען בגדרו, וממילא אין להסתפק באמירה זו של באת כוחה. בסיכומיהם אישרו ה"ה [redacted] כי בהתאם להסכמות הצדדים נמנעה רום ארד מלחייבם בהפרשי הצמדה בסך של 11,000 ₪, וכי יש להפחית סך זה מסכום הפיצוי בגין אי התאמות. בהתאם, ובהיעדר ביסוס ראייתי כאמור להצדקת הפחתת מלוא הסכום שנקבע בחוות דעת[redacted] בגין הפרגולה, אני מוצאת להעמיד הפיצוי על סך של 3,000 ₪.

באשר לטענת רום ארד בדבר חובה של אוריון לביצוע עבודות בהתאם לחשבון השינויים שנחתם בינה לבין ה"ה [redacted] – אין בכך כדי לפטור רום ארד מהתחייבותה המפורשת כלפי ה"ה [redacted] בעניין הפרגולות, כמפורט בחוות דעת [redacted] כפי שהרחבתי לעיל.

<u>אין מקום להרמת מסך ההתאגדות כנגד [redacted]</u>

64. כזכור, כנגד אוריון ניתן צו הקפאת הליכים. לטענת ה"ה [redacted] אין לאוריון או ל[redacted] כל אחריות לעניין הסבת המחסן. עם זאת, על בית המשפט להורות על הרמת מסך ההתאגדות שבין אוריון לבעליה, [redacted] בעניין יתר עילות התביעה (סעיפים 1, 6 לסיכומי התובעים). אך לא התרשמתי מקיומה של הצדקה לכך.

כלל האישיות המשפטית הנפרדת של רום ארד, המעוגן בסעיף 4 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, עומד בבסיס דיני החברות במשפט הישראלי. החריגים לכלל זה מוסדרים בסעיף 6 לחוק החברות, לפיו רשאי בית המשפט לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן, במקרים בהם שימוש באישיות המשפטית הנפרדת נעשה באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של רום ארד, או באופן הפוגע בתכלית רום ארד, תוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולת רום ארד לפרוע את חובותיה, כמבואר בסעיף.

[redacted]

בהתאם להוראות סעיף זה ולהלכה הפסוקה, השימוש בהרמת מסך ההתאגדות ייעשה במשורה ובזה במקרים חריגים בלבד, מתוך הכרה בחשיבות עקרון האישיות המשפטית הנפרדת (ראו, בין היתר 3807/12 *מרכז העיר אשדוד ק.א בע"מ נ' שמואל שמעון* (פורסם במאגרים 22.01.2015); ע"א 8 *נשאשיבי נ' רינראוי*, פ"ד סד(1) 398 (2010), פסקה 8 לחוות דעת כב' המשנה לנשיאה ריבלין ופסקאו 78 לחוות דעת כב' השופט דנציגר (בדעת מיעוט); ע"א 4263/04 *קיבוץ משמר העמק נ' מפרק אפרוחי בע"מ*, סג(1) 548 (2009), פסקאות 67 – 70 לחוות דעת כב' השופטת פרוקצ'יה). איני מתרשמת כי המקרה שלפני נמנה על המקרים המצדיקים סטייה מעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת והרמת מסך ההתאגדות.

ה"ה [redacted] נמנעו מלנמק בתצהיריהם ובסיכומיהם מדוע יש הצדקה להרמת מסך ההתאגדות, זולת הטענה כי העובדה כי אוריון מצויה בהקפאת הליכים מלמדת על הצדקת הרמת המסך. אך ברי, כי עצם היות אוריון בהקפאת הליכים אין בה כשלעצמה כדי להצדיק הרמת המסך.

65. בסיכומיהם הפנו ה"ה [redacted] באופן סתמי לבקשה מיום 11.9.16 שהוגשה בתיק , בגדרה התבקש צירופו של [redacted] כנתבע בהליך. אך ה"ה [redacted] נמנעו מלפרט בסיכומיהם את נימוקי הרמת המסך, ודי בכך כדי להביא לדחיית טענותיהם של ה"ה [redacted] בעניין.

למעלה מן הצורך, ולגופם של דברים, לא השתכנעתי כי די בטענות שפורטו בבקשה מיום 11.9.16 ובכתב התביעה המתוקן כדי להצדיק הרמת המסך הנתבעת.

ה"ה [redacted] טענו, כי [redacted] מודע לכך שאוריון מוגבלת בבנקים ומצויה לקראת הליך חדלות פירעון וכן כי אגב הסתבכותה של אוריון הקים [redacted] שתי חברות נוספות בשנת 2016, במסגרתן הוא ממשיך את פעילותו העסקית הרגילה (סעיף 10.1 לבקשה וסעיפים 119 – 120 לכתב התביעה המתוקן). עוד טענו ה"ה [redacted] בכתב התביעה המתוקן, כי בשנת 2016 ביצע [redacted] סדרה של פעולות מכוונות להעברת פעילות אוריון לידי החברות החדשות שהקים כאמור, תוך צבירת חובות, הגדלת אשראי, מימון דק והעדפת נושים אסורה, וכן תוך הסתתרות אישית חסרת תום לב מאחורי מסך ההתאגדות (סעיפים 114, 121 לכתב התביעה המתוקן).

אך אין ב עצם היותו של [redacted] מודע למצבה של אוריון נכון למועד הגשת הבקשה, או בעצם הקמתן של שתי חברות נוספות על ידי [redacted] בשנת 2016 – כדי לבסס הטענה כי [redacted] עשה שימוש באישיותה המשפטית

הנפרדת של אוריון באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה שלה, או באופן הפוגע בתכלית אוריון, תוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.

זאת מאחר שלא הוצג כל ביסוס ראייתי לטענה כי [redacted] היה מודע למצבה הכספי של אוריון במועדים הרלוונטיים לתביעה (האסמכתאות היחידות שהוצגו לעניין מתייחסות כולן למועדים המאוחרים להגשת כתב התביעה - תמלול שתי שיחות טלפון עם [redacted] מימים 19.7.16 ו- 21.7.16, וכן דו"ח BDI מ[redacted] בדבר מצבה של אוריון נכון למועד זה). אף לא הוצגה אסמכתא לכך ש[redacted] השתמש בחב[redacted] להמשכת פעילותו העסקית הרגילה או להברחת פעילות אליהן (זולת ראיה לעצם הקמתן של [redacted] נוספות). אפנה, בהקשר זה, לחקירתו הנגדית של [redacted] במהלכה אישר, כי אינו יודע מה הי[redacted] אוריון במועדים הרלוונטיים לתביעה, בשנים 2013 – 2014 (עמ' 133, שורה 19), וכן כי אינו יו[redacted] החברות שהוקמו בשנת 2016 ואופי פעילותן (עמ' 131, שורות 22, 24, עמ' 132, שורות 3, 5, 8, 0

66. מעבר לכך, לא הושג כל ביסוס ראייתי לכך ש[redacted] צבר חובות באוריון ופעל לנצל את האשראי הקיים באוריון על מנת להותיר את התחייבויותיה בלתי נפרעות, ולהגדלת אשראי ומימון דק תוך העדפת נושים אסורה, באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה שלה, או באופן הפוגע בתכלית אוריון, תוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה לפרוע את חובותיה.

אין בעצם שעבודם של כספים עתידיים המגיעים לאוריון מפרויקטים שונים במהלך שנת 2016 לטובת נושים שונים – עוד קודם להגשת התביעה – כדי ללמד על פגיעה או קיפוח של ה"ה [redacted] גם בהקשר זה אפנה, לחקירתו הנגדית של [redacted] במהלכה אישר, כי אינו יודע מה היה מצב אוריון במועדים הרלוונטיים לתביעה, כמפורט לעיל. בנוסף אפנה לתצהיר העדות הראשית שהוגש מטעם [redacted] במסגרתו הצהיר, כי לא פעל בכל דרך שיש בה כדי לרוקן את אוריון מפעילות, וכן כי לא פעל ליצירת מימון דק באוריון, להעדפת נושים, לצבירת חובות או להגדלת אשראים באוריון (סעיפים 55 – 56 לתצהיר[redacted]. עדות זו לא נסתרה. כאמור, לא הוצגה כל ראיה לביסוס טענותיהם של ה"ה [redacted] בעניין, ואף אין בעדות שמסר [redacted] בחקירתו הנגדית כדי להפריך האמור.

במאמר מוסגר, בבקשה מיום 11.9.16 עתרו ה"ר[redacted] לייחוס חובות אוריון ל[redacted] בהתאם להוראות סעיף 6(ג) לחוק החברות ומכוח הוראות חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 והוראות חוק המכר (דירות), התשל"ג-1973. גם בקשה זו נזנחה כמעט כליל בסיכומיהם של ה"ה [redacted] זולת על דרך הטענה הסתמית, לפיה "ככל ש[redacted] יטען כי מגיעים לו כספים מאוריון, הרי שבית המשפט יתבקש להפעיל את סמכותו הקבועה בסעיף 6(ג) לחוק". אך הבקשה לייחוס חובות אוריון ל[redacted] לא נכללה בסעדים שנתבעו בגדרה של התביעה, ואף לא הועלו טענות קונקרטיות מצד[redacted] כי מגיעים לו כספים מאוריון בגדרו של הליך זה, ועל כן אין בסיס למתן סעד זה.

עוד יצוין, כי בכתב התביעה המתוקן עתרו התובעים להטלת אחריות אישית על [redacted] כאורגן אוריון, מכוח דיני הנזיקין (סעיף 129 לכתב התביעה המתוקן), אך בסיכומיהם זנחו טענה זו כליל, ועל כן אין מקום להידרש לה.

67. מאחר שלא מצאתי הצדקה להרמת מסך ההתאגדות שבין אוריון ל[redacted] מתייתרת ההכרעה בסוגיית אחריותה של אוריון לליקויים, אי ההתאמות ולאיחור במסירה של הדירה. למעלה מן הצורך אבהיר, כי לא השתכנעתי כי אוריון נושאת באחריות חוזית כאמור כלפי ה"ה [redacted]

ה"ה [redacted] טענו בסיכומיהם כי אוריון מחויבת כלפיהם במישור החוזי, מכוח הוראת סעיף 3.3 להסכם המכר, אשר זו לשונה:

> "3.3 הקונה מצהיר כי נמסר לו שבדעת החברה להתקשר בהסכם עם קבלן לשם ביצוע עבודות הבניה (להלן: "הקבלן"), אשר על פיו יתחייב הקבלן בין היתר לבנות ולהקים את הבנין והדירה. לאור זאת מסכים הקונה שהקבלן יהה אחראי כלפיו בכל הקשור ו/ או הכרוך בעבודות הבניה, לרבות איכותם, לוח הזמנים למסירת הדירה ותיקון ליקויים, זאת מבלי לגרוע מאחריות החברה על פי הוראות הדין."

אך אוריון כלל לא היתה צד להסכם המכר, ואפילו שמה נפקד מהוראת סעיף 3.3 להסכם המכר האמורה. ברי כי אין בהסכמתם החד צדדית של ה"ה [redacted] כי אוריון תהא אחראית כלפיהם, כמפורט בסעיף זה, כדי לחייב את אוריון, ללא הסכמתה המפורשת לכך.

על כן אין בהוראת סעיף 3.3 להסכם המכר משום עוגן חוזי לתביעת אוריון בגין ליקויים, או בגין עיכוב במסירת הדירה. לבטח שאין בהוראה זו כדי לבסס תביעה כנגד אוריון בגין אי התאמות שבדירה, בניגוד להתחייבויותיה של החברה, כתוספת שיווקית למפרט הטכני. ואכן, [redacted] אישר בחקירתו הנגדית, כי אין כל התקשרות חוזית ישירה בין ה"ה [redacted] לבין אוריון (עמ' 114, שורה 18, עמ' 115, שורות 8, 16, עמ' 117, שורה 5), וכי אוריון לא היתה צד להסכמות הצדדים כפי שתועדו בפרוטוקול הפגישה מיום 5.8.14 ובחשבון שינויים מיום 14.8.14, אודותיהם הרחבתי לעיל (עמ' 119, שורות 19, 24).

יודגש, כי ה"ה [redacted] לא העלו טענות לחבותה של אוריון כלפיהם במישור הנזיקי, ומכל מקום, מאחר שאוריון לא השלימה את העבודות בדירה, ספק אם ניתן לייחס לה אחריות נזיקית לכשלים שאותרו. אפנה, בהקשר זה, לעדותו של [redacted] כי עבודות הגמר בדירה בוצעו גם בידי קבלנים אחרים, שאינם אוריון, בסעיף 24 לתצהיר [redacted] וכן בחקירתו הנגדית, בעמ' 122, שורות 17 – 22, עמ' 124, שורות 2 – 3), וכן אפנה לעדותו של עו"ד [redacted] בחקירתו הנגדית, כי אינו סבור כי אוריון היא שהשלימה את עבודות הגמר בדירה (עמ' 168, שורות 21 – 23). עדויות אלה מאששות את טענתו של [redacted] בחקירתו הנגדית, כי אוריון עצרה את העבודות

בדירה בשלב מאוד מוקדם, עם קבלת טופס 4, וקודם להשלמת עבודות הבניה בדירה (עמ' 213, שורות 22 – 23, עמ' 214, שורות 12 – 16)

<u>עגמת נפש</u>

68. מהשתלשלות העניינים שנסקרה לעיל עולה, כי בדירה מצויים ליקויים ואי התאמות שלא הוסדרו, ההזדמנויות שעמדו לחברה לתקנם, ואף לאחר פרסום חוות דעת המהנדס [redacted] עוד עולה, כי בעת מס הדירה, טרם הושלמו חלק מעבודות הגמר. אמנם לא היה בכך כדי להצדיק מתן פיצוי בגין איחור במס הדירה, כאמור, אך ראוי להתחשב בכך בפסיקת פיצוי בגין עגמת נפש. לאור האמור, ובשים לב לוותק ה אני מחייבת את רום ארד בפיצוי ה"ה [redacted] בסך של 20,000 ₪ בגין עוגמת נפש והטרחה שנגרמו להם בשל אירועים אלה. הפיצוי המתון מתחשב בדחיית חלקן הארי של טענות ה"ה [redacted] בתביעתם, ובהיקף הנזק הממוקד שנגרם.

<u>סוף דבר</u>

אני מחייבת את הנתבעת 1, רום ארד הנדסה בע"מ, בפיצוי התובעים, ה"ה [redacted], בסך של 103,645 (סך של 54,000 ₪ בגין הכשרת הסבת המחסן, סך של 66,489 ₪ בגין ליקויי בניה, סך של 29,645 ₪ בגין הסדרת התוספות בדירה וסך של 20,000 ₪ בגין עגמת נפש).

בנוסף, תשלם הנתבעת 1 לתובעים את שכ"ט המהנדס [redacted] בו נשאו התובעים, עלות הקלטות ישיבות ההוכחות ותמלולן, וכן שיעור של 10% משכר טרחת המומחים האדריכל [redacted] והשמאי [redacted]. כל זאת בכפוף להצגת אסמכתאות לתשלום. כמו כן תשלם הנתבעת 1 לתובעים שיעור של 10% מאגרת בית המשפט, כפי ששולמה, וכן שכר טרחת עו"ד בסך של 20,000 ₪.

אני מורה על דחיית התביעה נגד הנתבע 3, מר [redacted] ומחייבת את התובעים לשלם לנתבע 3 הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 25,000 ₪.

הסכומים הכוללים ישולמו בתוך שלושים יום.

בפסיקת ההוצאות ושכ"ט עו"ד התחשבתי בהתנהלות הצדדים. לצד זאת, התחשבתי בתוצאת פסק הדין, ובפער בינה לבין הסכום עליו הועמדה התביעה. פער זה מעמיד בספק את ההצדקה להיקף המשאבים שהושקעו בניהול הליך ממושך, מורכב ומרובה דיונים.

ניתן היום, ג' אייר תשפ"ג, 24 אפריל 2023, בהעדר הצדדים.

[redacted]



פנינה נויבירט